

3.5. Regime de Pessoal

O regime de pessoal será diferente conforme se trate de uma FP de direito público ou de direito privado.

a) Fundação pública de direito público = estatutário (= Autarquia): a fundação pública de direito público adota o regime estatutário, ou seja, seus servidores devem ser contratados mediante concurso público (servidores efetivos) e com direito à estabilidade após 3 anos de efetivo exercício (se aprovados no estágio probatório).

- Concurso público;
- Servidores públicos;
- Cargo público;
- Estatuto;
- Estágio probatório;
- Estabilidade.

b) Fundação pública de direito privado = celetista (CLT): a fundação pública de direito privado adota o regime celetista, ou seja, seus agentes públicos classificam-se como empregados públicos e, portanto, jamais adquirem a estabilidade (não são servidores estatutários).

Mesmo assim, deverá ser realizado concurso público, pois a Constituição Federal exige concurso público tanto para cargos públicos, quanto para empregos públicos (art. 37, II, CRFB/1988).

- Concurso público;
- Empregados públicos;
- Emprego público;
- CLT;
- Sem estágio probatório;
- Sem estabilidade.

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

3.6. Patrimônio

Também diferirá conforme se trate de uma FP de direito público ou de direito privado.

a) Fundação pública de direito público = bens públicos (art. 98, CC): os bens das fundações públicas de direito público classificam-se como públicos.

Os bens públicos possuem um regime jurídico especial, que lhes garantem as seguintes prerrogativas (elas serão estudadas em Direito Administrativo II, no tópico "Bens Públicos"):

- Inalienabilidade ou alienação condicionada;

- *Impenhorabilidade;*
- *Não onerabilidade; e*
- *Imprescritibilidade.*

b) Fundação pública de direito privado (art. 98, CC): as fundações públicas de direito privado possuem bens que se classificam como privados.

Portanto, a princípio, tais bens podem sofrer livre disposição: art. 1.228, *caput*, CC.

→ Bens privados afetados ao serviço público: todavia, os bens que são utilizados pela fundações públicas de direito privado para a prestação de serviços públicos, apesar de serem bens privados, também possuem as quatro prerrogativas dos bens públicos = alienação condicionada + impenhorabilidade + não onerabilidade + imprescritibilidade.

Ex: um prédio de propriedade de uma fundação pública de direito privado, no qual está instalada a sua sede, possui as prerrogativas públicas, pois esse prédio está afetado ao serviço público; mas um terreno de propriedade dessa mesma fundação, que esteja sem utilização, não gozará das prerrogativas dos bens públicos.

Código Civil

Art. 98. São públicos os bens do domínio nacional pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno; todos os outros são particulares, seja qual for a pessoa a que pertencerem.

Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.

§ 1º [...]

3.7. Responsabilidade Civil

Sejam de direito público ou de direito privado, a responsabilidade civil das fundações públicas sempre será objetiva, pois ambas se enquadram no § 6º do art. 37 da CRFB/1988.

Na responsabilidade objetiva basta provar o fato, o dano e o nexo causal entre eles – não é preciso provar a culpa *lato sensu*: dolo ou culpa em sentido estrito (negligência, imprudência ou imperícia).

a) Fundação pública de direito público: sua responsabilidade é objetiva porque elas são pessoas jurídicas de direito público.

b) Fundação pública de direito privado: sua responsabilidade é objetiva porque elas sempre pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos.

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988

Art. 37. [...]

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

3.8. Imunidade Tributária

a) Impostos (art. 150, VI, 'a', c/c § 2º, CRFB/1988): as fundações públicas – tanto as de direito público quanto as de direito privado – possuem imunidade tributária, de modo que seu patrimônio, renda e serviços não podem ser tributados por impostos.

Portanto, as autarquias não pagam impostos, mas as outras quatro espécies de tributos sim:

- *Impostos (não pagam);*
- *Taxas (pagam);*
- *Contribuições de melhoria (pagam);*
- *Empréstimos compulsórios (pagam); e*
- *Contribuições especiais (pagam).*

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

VI - instituir impostos sobre:

a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros;

[...]

§ 2º A vedação do inciso VI, 'a', é extensiva às autarquias e às fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços, vinculados a suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes.

3.9. Prerrogativas Processuais

Aqui, mais uma vez, dependerá do fato de se tratar de uma fundação pública de direito público ou de uma fundação pública de direito privado.

a) Fundação pública de direito público: como são pessoas jurídicas com natureza de direito público, as fundações públicas de direito público gozam de todas as prerrogativas processuais da Administração Pública (Fazenda Pública), quais sejam:

- *Prazo em dobro (art. 183, caput, CPC);*
- *Intimação pessoal (art. 183, § 1º, CPC); e*
- *Reexame necessário (art. 496, CPC).*

b) Fundação Pública de direito privado: as fundações públicas de direito privado são como qualquer pessoa jurídica de direito privado (empresa) e, portanto, não possuem prerrogativas processuais.

4. EMPRESAS ESTATAIS

4.1. Conceito

a) Empresas estatais: empresas estatais são todas e quaisquer entidades civis ou comerciais sob o controle acionário do Estado (Poder Público), englobando as empresas públicas e as sociedades de economia mista, as suas subsidiárias, bem como as demais sociedades controladas pelo Poder Público.

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988

Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei.

§ 1º A lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias que explorem atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços, dispondo sobre:

I - sua função social e formas de fiscalização pelo Estado e pela sociedade;

II - a sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários;

III - licitação e contratação de obras, serviços, compras e alienações, observados os princípios da administração pública;

IV - a constituição e o funcionamento dos conselhos de administração e fiscal, com a participação de acionistas minoritários;

V - os mandatos, a avaliação de desempenho e a responsabilidade dos administradores.

§ 2º As empresas públicas e as sociedades de economia mista não poderão gozar de privilégios fiscais não extensivos às do setor privado.

§ 3º A lei regulamentará as relações da empresa pública com o Estado e a sociedade.

§ 4º A lei reprimirá o abuso do poder econômico que vise à dominação dos mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros.

§ 5º A lei, sem prejuízo da responsabilidade individual dos dirigentes da pessoa jurídica, estabelecerá a responsabilidade desta, sujeitando-a às punições compatíveis com sua natureza, nos atos praticados contra a ordem econômica e financeira e contra a economia popular.

Decreto-lei Federal N.º 200/1967

Art. 5º Para os fins desta lei, considera-se:

II - Empresa Pública: a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, com patrimônio próprio e capital exclusivo da União, criado por lei para a exploração de atividade econômica que o Governo seja levado a exercer por força de contingência ou de conveniência administrativa podendo revestir-se de qualquer das formas admitidas em direito.

III - Sociedade de Economia Mista: a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, criada por lei para a exploração de atividade econômica, sob a forma de sociedade anônima, cujas ações com direito a voto pertençam em sua maioria à União ou a entidade da Administração Indireta.

4.2. Objeto

Podem ser dois os objetos de uma empresa pública ou de uma sociedade de economia mista.

a) Exploração de atividade econômica: as empresas estatais podem ser criadas para a exploração de atividade econômica pelo Poder Público, competindo no mercado com as pessoas jurídicas de direito privado.

Mas a criação de empresas estatais para a exploração de atividade econômica somente é admitida quando necessária para:

→ Imperativos da segurança nacional: o imperativo da segurança nacional está ligado à defesa do território e à liberdade da população.

→ Relevante interesse coletivo: o relevante interesse coletivo está ligado àquilo que foi estabelecido no programa do plano político-partidário escolhido pelo povo no processo eleitoral.

b) Prestação de serviços públicos: as empresas públicas e as sociedades de economia mista também podem ser criadas para a prestação de serviços públicos, ou seja, com a finalidade de atender as necessidades da sociedade, quais sejam, saúde, educação, transporte, segurança, energia elétrica, água, telefonia, captação e tratamento de esgoto e lixo, compensação bancária, administração da justiça, serviços funerários, controle do tráfego marítimo e aéreo...

c) Exemplos:

→ *Empresas públicas:* Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES); Caixa Econômica Federal (CEF); Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa); Empresa de Correios e Telégrafos (ECT)...

→ *Sociedades de economia mista:* Banco do Brasil (BB); Banco do Nordeste; Eletrobras; Petrobras...

4.3. Criação e Extinção

a) Criação (art. 37, XIX, segunda parte, CRFB/1988): primeiro deve haver uma lei autorizativa, ou seja, uma lei que apenas autorizará o Poder Público a criar a empresa pública ou a sociedade de economia mista – ou seja, o Poder Legislativo aprovará uma lei autorizando o Poder Executivo a criar qualquer uma delas quando achar pertinente.

Depois, como ambas possuem natureza jurídica de direito privado, sua criação efetiva ocorre da mesma forma que se dá a criação de qualquer pessoa jurídica de direito privado, qual seja, com a inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas (*caput* do art. 45 do CC).

→ *Lei autorizativa;* e

→ *Inscrição do ato constitutivo.*

→ Cuidado: o Decreto-lei Federal N.º 200/1967 menciona que a empresa pública e a sociedade de economia mista serão criadas por lei; todavia, essa exigência restou superada pela CRFB/1988, que exige lei unicamente para autorizar o Ente Federado a instituir as mesmas, sendo que sua efetiva criação dar-se-á com a inscrição do ato constitutivo junto ao Registro Civil das Pessoas Jurídicas.

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

XIX - somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação;

Código Civil

Art. 45. Começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro, precedida, quando necessário, de autorização ou aprovação do Poder Executivo, averbando-se no registro todas as alterações por que passar o ato constitutivo.

b) Extinção: novamente se aplica o princípio da simetria ou do paralelismo das formas, ou seja, a extinção de uma empresa pública ou de uma sociedade de economia mista ocorre do mesmo jeito que sua criação, vale dizer, mediante averbação do ato de extinção junto ao respectivo registro (parte final do art. 45 do CC).

4.4. Natureza Jurídica

a) Direito privado (art. 173, § 1º, II, CRFB/1988): as empresas estatais sempre possuem natureza jurídica de direito privado: "a sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários;"

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988

Art. 173. [...]

§ 1º A lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias que explorem atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços, dispondo sobre:

II - a sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários;

4.5. Regime de Pessoal

a) Celetista (CLT): as empresas estatais adotam o regime celetista, ou seja, seus agentes públicos classificam-se como empregados públicos e, portanto, jamais adquirem a estabilidade (não são servidores estatutários).

Mesmo assim, deverá ser realizado concurso público, pois a Constituição Federal exige concurso público tanto para cargos públicos, quanto para empregos públicos (art. 37, II, CRFB/1988).

- Concurso público;
- Empregados públicos;
- Emprego público;
- CLT;
- Sem estágio probatório;
- Sem estabilidade.

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

4.6. Patrimônio

a) Bens privados (art. 98, CC): as empresas públicas e as sociedades de economia mista possuem bens que se classificam como privados.

Portanto, a princípio, tais bens podem sofrer livre disposição: art. 1.228, *caput*, CC.

→ Bens privados afetados ao serviço público: todavia, os bens que são utilizados pela empresas estatais para a prestação de serviços públicos, apesar de serem bens privados, também possuem as quatro prerrogativas dos bens públicos.

Ex: o prédio onde funciona uma agência da CEF (EP) ou do BB (SEM) não pode ser objeto de penhora em ação judicial.

Para relembrar, as quatro prerrogativas dos bens públicos são as seguintes:

→ *Inalienabilidade ou alienação condicionada;*

→ *Impenhorabilidade;*

→ *Não onerabilidade;* e

→ *Imprescritibilidade.*

Código Civil

Art. 98. São públicos os bens do domínio nacional pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno; todos os outros são particulares, seja qual for a pessoa a que pertencerem.

Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.

§ 1º [...]

4.7. Responsabilidade Civil

Aqui teremos uma diferenciação quando se tratar de empresa estatal prestadora de serviço público ou empresa estatal exploradora de atividade econômica.

a) Empresa estatal exploradora de atividade econômica: a responsabilidade civil da empresa pública e da sociedade de economia mista que seja exploradora de atividade econômica é igual a das empresas privadas (aqui não se aplica o § 6º do art. 37 do CRFB/1988).

→ Responsabilidade subjetiva (regra): é a regra para as empresas estatais exploradoras de atividade econômica, ou seja, deverá ser comprovado o fato, dano, nexo causal entre ambos e a culpa *lato sensu* (dolo ou culpa *stricto sensu*: negligência, imprudência e imperícia).

→ Responsabilidade objetiva (exceção): mas a responsabilidade será objetiva quando alguma norma específica determinar a sua incidência, como ocorre nos casos envolvendo as relações de consumo – incidência do CDC.

b) Empresa estatal prestadora de serviços públicos = objetiva (art. 37, § 6º, CRFB/1988): agora, quando se trata de empresa pública ou sociedade de economia mista que sejam prestadoras de serviços públicos, a responsabilidade sempre será objetiva, pois o § 6º do art. 37 da CRFB/1988 inclui as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos.

4.8. Imunidade Tributária

a) Não há: percebe-se que o § 2º do art. 150 da CRFB/1988 menciona que "A vedação do inciso VI, 'a', é extensiva às autarquias e às fundações [...]", sem incluir as empresas estatais.

Além do mais, se as empresas públicas e as sociedades de economia mista gozassem de imunidade tributária, criar-se-ia uma competição injusta entre elas e as demais empresas da iniciativa privada, pois estas não possuem imunidade tributária.

Ex: a CEF e o BB teriam uma vantagem indevida sobre as demais entidades bancárias que atuam no país.

4.9. Prerrogativas Processuais

a) Não há: como as empresas estatais sempre possuem natureza jurídica de direito privado, elas não gozam de qualquer prerrogativa processual.

4.10. Outras Questões

a) Capital: em relação ao capital, patrimônio, das empresas públicas e das sociedades de economia mista, deve-se observar o que abaixo segue.

→ *Empresa pública:*

- *Constituição:* a empresa pública sempre é constituída com capital unicamente público;
- *Patrimônio:* todavia, uma vez constituída, seus bens classificam-se como privados.

→ *Sociedade de economia mista:*

- *Constituição:* já a sociedade de economia mista é constituída com capital público e capital privado; é daí, inclusive, que provém a sua nomenclatura = "mista";
- *Patrimônio:* uma vez constituída, os bens da sociedade de economia mista também se classificam como privados.

b) Regime societário: aqui também há diferenças.

→ *Empresa pública:* pode adotar qualquer forma societária prevista em lei.

→ *Sociedade de economia mista:* a sociedade de economia mista deve adotar, obrigatoriamente, o regime de sociedade anônima (S/A).

c) Controle societário: sempre deve ser do Poder Público.

→ *Empresa Pública:* na empresa pública, o controle societário sempre permanece com o Ente Federado que a constituiu (U+E+DF+M).

→ *Sociedade de Economia Mista:* já na sociedade de economia mista, o controle societário pode permanecer tanto com o Ente Federado (U+E+DF+M), quanto com qualquer Entidade da Administração indireta (A+FP+EP).

Cuidar que, apesar de haver capital privado na sociedade de economia mista, seu controle acionário jamais poderá pertencer à iniciativa privada.

d) Finalidade lucrativa: aqui novamente temos diferenças.

→ *Empresa Pública:* não se exige que a empresa pública tenha finalidade lucrativa.

→ *Sociedade de Economia Mista:* já a sociedade de economia mista, sempre deve possuir finalidade lucrativa.

5. QUESTÕES

- 01) ()** Com a Reforma Administrativa trazida pela Emenda Constitucional 19/1998, inspirada em uma concepção neoliberal de política econômica, foi implementado o modelo de administração pública na forma gerencial.
- 02) ()** A administração pública burocrática é aquela que visa mais eficiência e agilidade na atuação administrativa, com ênfase na produção de resultados.
- 03) ()** A teoria mais aceita para explicar a relação que existe entre o servidor público e a pessoa jurídica do Estado que ele representa é a teoria da representação, caracterizada pela imputação volitiva.
- 04) ()** As autarquias são criadas diretamente por lei e se destinam a executar atividades típicas da administração pública que requerem, para um melhor funcionamento, gestão administrativa e financeira descentralizada.
- 05) ()** Os órgãos públicos possuem personalidade jurídica própria, razão pela qual respondem diretamente por seus atos.
- 06) ()** A atuação dos órgãos públicos é imputada às pessoas jurídicas a que pertencem.
- 07) ()** Quando um ente político cria, mediante lei, órgãos internos em sua própria estrutura para organizar a gestão administrativa, estamos diante do instituto da desconcentração administrativa.
- 08) ()** Todas as entidades que compõem a administração pública indireta dispõem de personalidade jurídica de direito público.
- 09) ()** As autarquias são criadas por lei e sempre têm personalidade jurídica de direito público.
- 10) ()** As empresas públicas são criadas por meio de decreto do chefe do Poder Executivo respectivo.
- 11) ()** Sociedades de economia mista possuem capital exclusivamente público, sendo destinadas à exploração de atividade econômica decorrente de contingência ou conveniência administrativa.
- 12) ()** A exploração direta de atividade econômica pelo Estado só é permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo.
- 13) ()** Na centralização administrativa, os serviços públicos são prestados diretamente pelos Entes, aos quais a Constituição Federal imputa a responsabilidade pela sua prestação.
- 14) ()** A descentralização ocorre quando os Entes Federados, responsáveis pela prestação dos serviços públicos, delegam essa atribuição para outras pessoas, quais sejam, as Entidades administrativas e os delegatários (particulares) de serviços públicos.
- 15) ()** Na desconcentração administrativa, temos a criação de órgãos internos para a distribuição das atividades dentro de uma mesma pessoa jurídica.

- 16) ()** A criação e extinção dos órgãos públicos nem sempre deve ocorrer por meio de lei, com participação do Poder Legislativo.
- 17) ()** A organização e o funcionamento dos órgãos públicos sempre podem ser realizados por meio de Decreto, ato privativo do Chefe do Executivo.
- 18) ()** Enquanto na descentralização não há subordinação da Entidade administrativa ao Ente federado, mas apenas controle finalístico, na desconcentração a subordinação sempre está presente.
- 19) ()** O Estado de Santa Catarina resolveu criar uma empresa pública voltada para a exploração de atividades econômicas relevantes. Foi, então, aprovada uma lei autorizativa e, após, o Poder Executivo estadual realizou a inscrição dos atos constitutivos da empresa no registro competente, estando a entidade em vias de iniciar suas atividades econômicas. Esse procedimento de criação da empresa pública foi correto?
- 20) ()** Uma empresa pública, para a contratação de pessoal, não precisa realizar concurso público.
- 21) ()** Para a criação de uma sociedade de economia mista, basta a inscrição dos atos constitutivos no registro competente.
- 22) ()** As empresas públicas e sociedades de economia mista, apesar de serem entidades administrativas de direito público, não poderão contar com privilégios fiscais e trabalhistas.
- 23) ()** O Poder Executivo do governo do nosso Estado resolveu criar uma nova universidade estadual sob a forma de fundação pública. A intenção é que referida fundação detenha personalidade jurídica de direito público. Você, na condição de Procurador Estadual, foi consultado para orientar a forma correta de constituição da referida fundação, indicando que primeiro deve ser editada lei ordinária autorizando a instituição da fundação pública de direito público e, após, a entidade deve ser criada através de inscrição do seu ato constitutivo no registro competente. Sua orientação está correta?
- 24) ()** Uma fundação pública não pode ter personalidade jurídica de direito público.
- 25) ()** A edição da lei ordinária específica é suficiente para a criação de uma fundação pública que detenha personalidade de direito público.
- 26) ()** A criação de Entidades administrativas, por se tratar de ato do Poder Executivo, não depende de participação do Poder Legislativo.
- 27) ()** Autarquia é uma pessoa jurídica de direito público, integrante da Administração Indireta, criada por lei específica para desempenhar funções que sejam próprias e típicas do Estado.
- 28) ()** Empresa Pública é uma pessoa jurídica de direito privado, integrante da Administração estatal indireta, criada por autorização legal, sob qualquer forma jurídica adequada a sua natureza, para que o Governo exerça atividades gerais de caráter econômico ou, em certas situações, execute a prestação de serviços públicos.

Q213691

Ano: 2011 Banca: FGV Órgão: OAB Prova: FGV - 2011 - OAB - Exame de Ordem Unificado - V - Primeira Fase

A estruturação da Administração traz a presença, necessária, de centros de competências denominados Órgãos Públicos ou, simplesmente, Órgãos. Quanto a estes, é correto afirmar que:

- () A) possuem personalidade jurídica própria, respondendo diretamente por seus atos.
- () B) suas atuações são imputadas às pessoas jurídicas a que pertencem.
- () C) não possuem cargos, apenas funções, e estas são criadas por atos normativos do ocupante do respectivo órgão.
- () D) não possuem cargos nem funções.

Q155413

Ano: 2011 Banca: FGV Órgão: OAB Prova: FGV - 2011 - OAB - Exame de Ordem Unificado - III - Primeira Fase

É correto afirmar que a desconcentração administrativa ocorre quando um ente político:

- () A) cria, mediante lei, órgãos internos em sua própria estrutura para organizar a gestão administrativa.
- () B) cria, por lei específica, uma nova pessoa jurídica de direito público para auxiliar a administração pública direta.
- () C) autoriza a criação, por lei e por prazo indeterminado, de uma nova pessoa jurídica de direito privado para auxiliar a administração pública.
- () D) contrata, mediante concessão de serviço público, por prazo determinado, uma pessoa jurídica de direito público ou privado para desempenhar uma atividade típica da administração pública.

Q171333

Ano: 2009 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: OAB Prova: CESPE - 2009 - OAB - Exame de Ordem - 2 - Primeira Fase

No que concerne à administração pública, assinale a opção correta.

- () A) As empresas públicas, cujos funcionários são regidos pelo regime dos servidores públicos da União, são criadas por meio de decreto do presidente da República.
- () B) Os órgãos públicos não são dotados de personalidade jurídica própria.
- () C) A Caixa Econômica Federal é pessoa jurídica de direito público interno.
- () D) O Banco do Brasil S.A., na qualidade de sociedade de economia mista controlada pela União, goza de privilégios fiscais não extensivos ao setor privado.

Q197086

Texto associado

"[...] compartimento na estrutura estatal a que são cometidas funções determinadas, sendo integrado por agentes que, quando as executam, manifestam a própria vontade do Estado." (José dos Santos Carvalho Filho. *Manual de Direito Administrativo*. 19º ed. Rio de Janeiro: Lemen Juris, 2008, p. 13)

O trecho acima se refere ao conceito de

- () A) função pública.
- () B) órgão público.
- () C) pessoa de direito público.
- () D) agente público.

Q299407

Ano: 2007 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: OAB Prova: CESPE - 2007 - OAB - Exame de Ordem - 2 - Primeira Fase

Acerca dos órgãos públicos, assinale a opção correta.

- () A) A teoria que melhor explica a relação existente entre o servidor público e a pessoa jurídica do Estado é a teoria da representação, cuja característica principal consiste no princípio da imputação volitiva. Assim, a vontade do órgão público é imputada à pessoa jurídica a cuja estrutura pertence, já que aquele estaria agindo em seu nome.
- () B) A organização da administração pública direta, no que se refere à estruturação dos órgãos e competência, é matéria reservada à lei.

- () C) É correto, do ponto de vista da natureza jurídica do órgão, afirmar que “João propôs uma ação de rito ordinário contra a receita federal”.
- () D) Alguns órgãos públicos têm capacidade processual, já que são titulares de direitos subjetivos próprios a serem defendidos.

Q208752

Ano: 2006 Banca: ND Órgão: OAB-DF Prova: ND - 2006 - OAB-DF - Exame de Ordem - 3 - Primeira Fase

A distribuição de atribuições entre os vários órgãos integrantes do Ministério da Fazenda caracteriza:

- () A) delegação de competências;
- () B) descentralização administrativa;
- () C) avocação administrativa;
- () D) desconcentração administrativa.

Q208751

Ano: 2006 Banca: ND Órgão: OAB-DF Prova: ND - 2006 - OAB-DF - Exame de Ordem - 3 - Primeira Fase

Não possui personalidade jurídica de direito público:

- () A) Município;
- () B) Agência Nacional de Águas (agência reguladora federal);
- () C) Território;
- () D) Presidência da República.

Q304934

Ano: 2012 Banca: FGV Órgão: OAB Prova: FGV - 2012 - OAB - Exame de Ordem Unificado - VIII - Primeira Fase

Quanto às pessoas jurídicas que compõem a Administração Indireta, assinale a afirmativa correta.

- () A) As autarquias são pessoas jurídicas de direito público, criadas por lei.
- () B) As autarquias são pessoas jurídicas de direito privado, autorizadas por lei.
- () C) As empresas públicas são pessoas jurídicas de direito público, criadas por lei.
- () D) As empresas públicas são pessoas jurídicas de direito privado, criadas para o exercício de atividades típicas do Estado.

Q197090

Ano: 2008 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: OAB Prova: CESPE - 2008 - OAB - Exame de Ordem - 2 - Primeira Fase

Assinale a opção correta a respeito da organização da administração pública federal.

- () A) Todas as entidades que compõem a administração pública indireta dispõem de personalidade jurídica de direito público, vinculando-se ao ministério em cuja área de competência estiver enquadrada sua principal atividade.
- () B) As autarquias destinam-se à execução de atividades típicas da administração pública que requeiram, para seu melhor funcionamento, gestão administrativa e financeira descentralizada.
- () C) As sociedades de economia mista têm patrimônio próprio e capital exclusivo da União, destinando-se à exploração de atividade econômica que o governo seja levado a exercer por força de contingência ou conveniência administrativa.
- () D) Os órgãos que compõem a estrutura da Presidência da República, apesar de serem dotados de personalidade jurídica, estão submetidos à supervisão direta do ministro- chefe da Casa Civil.

Q207868

Ano: 2007 Banca: VUNESP Órgão: OAB-SP Prova: VUNESP - 2007 - OAB-SP - Exame de Ordem - 2 - Primeira Fase

Sobre a Administração Indireta, é correto afirmar que:

- () A) as autarquias são criadas por lei e têm personalidade jurídica de direito público.
- () B) as fundações têm necessariamente personalidade jurídica de direito público, assemelhando-se às autarquias.
- () C) as sociedades de economia mista são criadas por lei, independentemente do registro de seus atos constitutivos na junta comercial.
- () D) mediante autorização de lei específica, as empresas públicas podem contar com participação privada em seu capital.

Q583035

Ano: 2015 Banca: FGV Órgão: OAB Prova: FGV - 2015 - OAB - Exame de Ordem Unificado - XVIII - Primeira Fase

O Estado XYZ pretende criar uma nova universidade estadual sob a forma de fundação pública. Considerando que é intenção do Estado atribuir personalidade jurídica de direito público a tal fundação, assinale a afirmativa correta.

- () A) Tal fundação há de ser criada com o registro de seus atos constitutivos, após a edição de lei ordinária autorizando sua instituição.
- () B) Tal fundação há de ser criada por lei ordinária específica.
- () C) Não é possível a criação de uma fundação pública com personalidade jurídica de direito público.
- () D) Tal fundação há de ser criada por lei complementar específica.

Q947728

Ano: 2018 Banca: FGV Órgão: OAB Prova: FGV - 2018 - OAB - Exame de Ordem Unificado - XXVII - Primeira Fase

No ano corrente, a União decidiu criar uma nova empresa pública, para a realização de atividades de relevante interesse econômico. Para tanto, fez editar a respectiva lei autorizativa e promoveu a inscrição dos respectivos atos constitutivos no registro competente. Após a devida estruturação, tal entidade administrativa está em vias de iniciar suas atividades.

Acerca dessa situação hipotética, na qualidade de advogado(a), assinale a afirmativa correta.

- () A) A participação de outras pessoas de direito público interno, na constituição do capital social da entidade administrativa, é permitida, desde que a maioria do capital votante permaneça em propriedade da União.
- () B) A União não poderia ter promovido a inscrição dos atos constitutivos no registro competente, na medida em que a criação de tal entidade administrativa decorre diretamente da lei.
- () C) A entidade administrativa em análise constitui uma pessoa jurídica de direito público, que não poderá contar com privilégios fiscais e trabalhistas.
- () D) Os contratos com terceiros destinados à prestação de serviços para a entidade administrativa, em regra, não precisam ser precedidos de licitação.

Q829485

Ano: 2017 Banca: FGV Órgão: OAB Prova: FGV - 2017 - OAB - Exame de Ordem Unificado - XXIII - Primeira Fase

O Estado Alfa, mediante a respectiva autorização legislativa, constituiu uma sociedade de economia mista para o desenvolvimento de certa atividade econômica de relevante interesse coletivo.

Acerca do Regime de Pessoal de tal entidade, integrante da Administração Indireta, assinale a afirmativa correta.

- () A) Por se tratar de entidade administrativa que realiza atividade econômica, não será necessária a realização de concurso público para a admissão de pessoal, bastando processo seletivo simplificado, mediante análise de currículo.
- () B) É imprescindível a realização de concurso público para o provimento de cargos e empregos em tal entidade administrativa, certo que os servidores ou empregados regularmente nomeados poderão alcançar a estabilidade mediante o preenchimento dos requisitos estabelecidos na Constituição da República.
- () C) Deve ser realizado concurso público para a contratação de pessoal por tal entidade administrativa, e a remuneração a ser paga aos respectivos empregados não pode ultrapassar o teto remuneratório estabelecido na Constituição da República, caso sejam recebidos recursos do Estado Alfa para pagamento de despesas de pessoal ou de custeio em geral.
- () D) A entidade administrativa poderá optar entre o regime estatutário e o regime de emprego público para a admissão de pessoal, mas, em qualquer dos casos, deverá realizar concurso público para a seleção de pessoal.

Q530761

Ano: 2015 Banca: FGV Órgão: OAB Prova: FGV - 2015 - OAB - Exame de Ordem Unificado - XVII - Primeira Fase

Após autorização em lei, o Estado X constituiu empresa pública para atuação no setor bancário e creditício. Por não possuir, ainda, quadro de pessoal, foi iniciado concurso público com vistas à seleção de 150 empregados, entre economistas, administradores e advogados.

A respeito da situação descrita, assinale a afirmativa correta.

- () A) Não é possível a constituição de empresa pública para exploração direta de atividade econômica pelo Estado.
- () B) A lei que autorizou a instituição da empresa pública é, obrigatoriamente, uma lei complementar, por exigência do texto constitucional.
- () C) Após a Constituição de 1988, cabe às empresas públicas a prestação de serviços públicos e às sociedades de economia mista cabe a exploração de atividade econômica.
- () D) A empresa pública que explora atividade econômica sujeita-se ao regime trabalhista próprio das empresas privadas, o que não afasta a exigência de concurso público.

Q349735

Ano: 2013 Banca: FGV Órgão: OAB Prova: FGV - 2013 - OAB - Exame de Ordem Unificado - XII - Primeira Fase

O Estado ABCD, com vistas à interiorização e ao incremento das atividades econômicas, constituiu empresa pública para implantar distritos industriais, elaborar planos de ocupação e auxiliar empresas interessadas na aquisição dessas áreas. Considerando que esse objeto significa a exploração de atividade econômica pelo Estado, assinale a afirmativa correta.

- () A) Não é possível a exploração de atividade econômica por pessoa jurídica integrante da Administração direta ou indireta.
- () B) As pessoas jurídicas integrantes da Administração indireta não podem explorar atividade econômica.
- () C) Dentre as figuras da Administração Pública indireta, apenas a autarquia pode desempenhar atividade econômica, na qualidade de agência reguladora.
- () D) A constituição de empresa pública para exercer atividade econômica é permitida quando necessária ao atendimento de relevante interesse coletivo.

Q304939

Ano: 2012 Banca: FGV Órgão: OAB Prova: FGV - 2012 - OAB - Exame de Ordem Unificado - VIII - Primeira Fase

O Presidente da República, considerando necessária a realização de diversas obras de infraestrutura, decide pela criação de uma nova Sociedade de Economia Federal e envia projeto de lei para o Congresso Nacional. Após a sua regular tramitação, o Congresso aprova a criação da Companhia "X".

Considerando a situação apresentada, assinale a afirmativa correta.

- () A) A Companhia "X" poderá editar os decretos de utilidade pública das áreas que necessitam ser desapropriadas para consecução do objeto que justificou sua criação.
- () B) A Companhia "X" está sujeita à licitação e à contratação de obras, serviços, compras e alienações, observados os princípios da administração.
- () C) A Companhia "X" será necessariamente uma sociedade de propósito específico (SPE) e a maioria do capital social deverá sempre pertencer à União.
- () D) A Companhia "X" possui foro privilegiado e eventuais demandas judiciais correrão perante a Justiça Federal.

Q304857

Ano: 2012 Banca: FGV Órgão: OAB Prova: FGV - 2012 - OAB - Exame de Ordem Unificado - IX - Primeira Fase

Atento à crescente especulação imobiliária, e ciente do sucesso econômico obtido pelas construtoras do País com a construção de imóveis destinados ao público de alta renda, o Estado "X" decide ingressar nesse lucrativo mercado. Assim, edita uma lei autorizando a criação de uma empresa pública e, no mesmo ano, promove a inscrição dos seus atos constitutivos no registro das pessoas jurídicas.

Assinale a alternativa que apresenta a alegação que as construtoras privadas, incomodadas pela concorrência de uma empresa pública, poderiam apresentar.

- () A) A nulidade da constituição daquela pessoa jurídica, uma vez que as pessoas jurídicas estatais só podem ser criadas por lei específica.
- () B) O objeto social daquela empresa só poderia ser atribuído a uma sociedade de economia mista e não a uma empresa pública.
- () C) Os pressupostos de segurança nacional ou de relevante interesse coletivo na exploração daquela atividade econômica não estão presentes.
- () D) A criação da empresa pública não poderia ter ocorrido no mesmo ano em que foi editada a lei autorizativa.

Q261974

Ano: 2012 Banca: FGV Órgão: OAB Prova: FGV - 2012 - OAB - Exame de Ordem Unificado - VII - Primeira Fase

Em relação às entidades que compõem a administração indireta, assinale a alternativa correta.

- () A) Para a criação de autarquias, é necessária a edição de uma lei autorizativa e posterior registro de seus atos constitutivos no respectivo registro como condição de sua existência.
- () B) Para criação de uma empresa pública, é necessária a edição de uma lei específica sem a exigência de registro de seus atos constitutivos no respectivo registro por se tratar de uma pessoa jurídica de direito público.
- () C) Para criação de uma sociedade de economia mista, é necessária a edição de uma lei autorizativa e registro de seus atos constitutivos no respectivo registro por se tratar de uma pessoa jurídica de direito privado.
- () D) Por serem pessoas jurídicas, todas necessitam ter seus respectivos atos constitutivos registrados no respectivo registro como condição de sua existência.

Q209110

Ano: 2006 Banca: ND Órgão: OAB-DF Prova: ND - 2006 - OAB-DF - Exame de Ordem - 1 - Primeira Fase

Assinale a assertiva CORRETA:

- () A) as empresas públicas e as sociedades de economia mista desenvolvem atividades econômicas e prestam serviços públicos;
- () B) o processo administrativo obedece ao princípio da verdade formal;
- () C) a Reforma Administrativa implementada pela Emenda Constitucional n. 19, de 1998, afastou o modelo de administração sistêmica ou gerencial em favor do modelo de administração burocrático-patrimonialista;
- () D) as agências reguladoras integram a Administração Pública Direta.

ATOS ADMINISTRATIVOS

1. CONCEITO

- 1.1. Atos Administrativos $\neq$ Atos da Administração
- 1.2. Atos Administrativos = Poder Executivo

2. ATRIBUTOS

- 2.1. Tipicidade
- 2.2. Presunção de Legitimidade e de Veracidade
- 2.3. Imperatividade
- 2.4. Autoexecutoriedade
- 2.5. Questões

3. ELEMENTOS

- 3.1. Competência
- 3.2. Finalidade
- 3.3. Motivo
- 3.4. Forma
- 3.5. Objeto
- 3.6. Questões

4. CLASSIFICAÇÃO

- 4.1. Ato Vinculado
- 4.2. Ato Discricionário
- 4.3. Quanto aos Destinatários
- 4.4. Quanto à Formação da Vontade
- 4.5. Quanto à Perfeição, Validade e Eficácia
- 4.6. Quanto à Imperatividade
- 4.7. Questões

5. EXTINÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS

- 5.1. Anulação
- 5.2. Revogação
- 5.3. Diferença entre Anulação e Revogação
- 5.4. Caducidade
- 5.5. Contraposição
- 5.6. Renúncia
- 5.7. Cassação
- 5.8. Questões

1. CONCEITO

Ato administrativo é toda manifestação unilateral de vontade do Estado (Poder Executivo) ou de quem o represente que, valendo-se das prerrogativas de direito público, tenha por fim criar direitos ou impor obrigações.

a) Unilateral: quando falamos que o ato administrativo é uma manifestação de vontade unilateral, significa que a Administração Pública (Poder Executivo) manifesta sua vontade sozinha, sem depender da anuência de terceiros – do Poder Legislativo, do Poder Judiciário ou do particular (não é um contrato) que sofrerá a imposição do ato.

Ou seja, o Poder Executivo irá impor o ato valendo-se da sua supremacia (das prerrogativas de direito público).

b) Prerrogativas: as prerrogativas de direito público são a superioridade que a Administração possui em relação aos particulares.

É a supremacia do interesse público (da coletividade) sobre o interesse particular egoístico de um único indivíduo.

c) Direito público: o direito privado não combina com os atos administrativos, pois no direito privado o que prevalece é o encontro ou a autonomia de vontades, a negociação. Ou seja, no direito privado, se uma das partes não está de acordo, o negócio jurídico não acontece (ex.: contrato).

Nos atos administrativos o que vigora é o direito público, do qual decorrem as prerrogativas da Administração. Dito de outro modo, são as regras de direito público que preveem as prerrogativas do Poder Público, sua supremacia sobre o particular.

- Cuidado: direito privado: mas o direito privado estará presente nos atos da Administração, que veremos abaixo (atos administrativos ≠ atos da administração).

d) Estado ou terceiros: por fim, os atos administrativos podem ser praticados pela Administração Pública (através dos agentes públicos) ou por particulares que estejam no exercício das prerrogativas públicas (ex.: delegatários de serviços públicos, como as permissionárias e concessionárias de serviços públicos, que estudamos no material sobre "Serviços Públicos").

1.1. Atos Administrativos ≠ Atos da Administração

Atos administrativos são uma espécie do gênero atos da Administração.

Os atos da administração (gênero) dividem-se em atos jurídicos ou ajurídicos.

a) Atos jurídicos: os atos jurídicos da Administração Pública (Poder Executivo) podem ser praticados tanto sob a égide do direito privado quanto do direito público.

- Atos jurídicos de direito privado (atos de gestão): são os atos praticados pela Administração Pública nos quais ela está em igualdade de condições com o particular, ou seja, nos quais não incidem as prerrogativas de direito público.

Esses atos também são chamados de atos de gestão privada, onde haverá um encontro de vontades (negócio) entre o Poder Executivo e o particular.

Ex.: contrato de locação de um prédio, que é disciplinado por norma de direito privado (a Lei de Locações: n.º 8.245/1991) e não por norma de direito público – não existe norma de direito público que preveja prerrogativas em favor da Administração para os contratos de locação; dessa forma, aplica-se o direito privado (Lei Nacional n.º 8.245/1991), onde vigora a igualdade de condições entre as partes.

Portanto, o Poder Público também pratica atos jurídicos de direito privado; mas esses atos não se confundem com os atos administrativos que são o objeto do nosso estudo neste material.

- *Atos jurídicos de direito público*: aqui estão os atos administrativos que interessam ao nosso estudo, nos quais o Poder Público (Executivo) age com supremacia sobre o particular, valendo-se das prerrogativas de direito público que lhe são asseguradas pelas normas de direito público.

b) Atos ajurídicos: são os atos que não são jurídicos:

- *Atos materiais*: os atos materiais são atos de execução de atividades administrativas, como a construção de uma escola.

- *Atos de conhecimento, opinião, juízo e valor*: são atos que atestam fatos, exprimem opiniões...

1.2. Atos Administrativos = Poder Executivo

Quem pratica os atos administrativos é o Poder Executivo.

A função típica do Poder Executivo é administrar a coisa pública, o que ele faz através da emissão de atos administrativos.

Portanto, quando falamos de atos administrativos, estamos falando de atos praticados pelo Poder Executivo; não do Poder Legislativo nem do Poder Judiciário.

Para lembrar:

- Poder Executivo da União: o chefe é o Presidente da República;
- Poder Executivo dos estados: o chefe é o Governador;
- Poder Executivo do Distrito Federal: o chefe é o Governador;
- Poder Executivo dos municípios: o chefe é o Prefeito.

2. ATRIBUTOS

Atributos são as características que o ato administrativo possui, quais sejam ("P.A.T.I"):

- Presunção de legitimidade e de veracidade;
- Autoexecutoriedade;
- Tipicidade; e
- Imperatividade.

Para facilitar a compreensão do que seja cada um dos quatro atributos, os estudaremos numa ordem diferente da acima.

2.1. Tipicidade

Tipicidade significa que o ato administrativo deve corresponder a figuras previamente definidas em lei – é a mesma tipicidade do Direito Penal: "*tipo é o modelo legal da conduta proibida.*"

A tipicidade também é uma decorrência do princípio da legalidade e representa uma garantia ao administrado (ao particular), pois indica que a Administração (Poder Executivo) somente pode fazer o que está previsto nas normas jurídicas (o que elas permitem).

Oportuno rememorar a doutrina clássica de Hely Lopes Meirelles sobre o princípio da legalidade:

Na Administração Pública não há liberdade nem vontade pessoal. Enquanto na administração particular é lícito fazer tudo que a lei não proíbe, na Administração Pública só é permitido fazer o que a lei autoriza.

→ Sempre (universal): a tipicidade é universal, ou seja, sempre está presente nos atos administrativos (em todos eles).

2.2. Presunção de Legitimidade e de Veracidade

a) Presunção de legitimidade (lei, norma jurídica): como a atuação administrativa (Poder Executivo) somente ocorre quando autorizada pelas normas jurídicas (lei em sentido amplo), presume-se que todos os atos administrativos praticados pelo Poder Público são legítimos, pois, em tese, foram praticados respeitando as normas jurídicas (são legais).

b) Presunção de veracidade (fatos): a presunção de veracidade refere-se aos fatos alegados pela Administração Pública para a prática dos atos administrativos, os quais se presumem verdadeiros.

Portanto, também se presume que sejam verdadeiros os fatos alegados pelo Poder Executivo para a prática do ato administrativo.

Ex.: multa de trânsito porque o motorista estava ao celular – presume-se que esse fato atestado pelo policial (representante do Poder Executivo) é verdadeiro e, portanto, o motorista deve ser multado.

c) Mera presunção (iuris tantum): mas tanto a legitimidade (norma jurídica) quanto a veracidade (fato) são apenas presumidas ou relativas, o que também é chamado de presunção *iuris tantum* ($\neq$ *iuris et de iuri*), e, por isso, admitem prova em contrário.

Isso significa dizer que a pessoa afetada pelo ato administrativo praticado pela Administração Pública (Poder Executivo) pode provar que uma ou ambas as presunções não são verdadeiras.

Ex.: o motorista multado por falar ao celular pode provar que naquele dia nem estava naquele local (estava viajando, em outro estado).

- Inversão do ônus da prova: como sabido, a regra geral de Direito é que aquele que alega deve provar (art. 373, CPC); mas em relação aos atos administrativos, como eles gozam das presunções de legitimidade e veracidade, a Administração Pública nada precisa provar, cabendo à pessoa afetada pelo ato demonstrar o contrário se assim quiser.

Portanto, em relação aos atos administrativos, ocorre a inversão do ônus da prova, cabendo ao particular provar que a alegação da Administração não é verdadeira e/ou que não está em conformidade com a legislação (legitimidade).

Código de Processo Civil

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

→ Sempre (universal): as presunções de legitimidade e veracidade são universais, o que significa dizer que estão presentes em todos os atos administrativos (em todos eles).

Mas cuidado para não confundir as presunções universal, absoluta e relativa:

- Presunção universal (todos): presunção universal é aquela que está presente em todas as situações, como é o caso das presunções de legitimidade e veracidade, que estão presentes em todos os atos administrativos.

- Presunção absoluta ("iuris et de iuri"): a presunção absoluta ou *iuris et de iuri* é aquela que não admite prova em contrário, ou seja, são presunções absolutas, plenas, soberanas, incondicionais... sobre as quais não cabe discussão.

- Presunção relativa ("iuris tantum"): por fim, a presunção relativa ou *iuris tantum* é aquela que admite prova em contrário, como é o caso das presunções de legitimidade e veracidade.

Portanto, as presunções de legitimidade e veracidade são universais (estão presentes em todos os atos administrativos) e relativas (aditem prova em contrário).

2.3. Imperatividade

Por fim, a imperatividade é a possibilidade que a Administração Pública (Poder Executivo) possui de impor-se a terceiros, independentemente da vontade dos mesmos.

A imperatividade provém do poder de império da Administração Pública: "A Administração não pede, ela manda."

Ou seja, o ato administrativo independe da anuência do particular: o ato administrativo é imposto pela Administração Pública (Poder Executivo) ao particular mesmo que este não concorde – é o poder extroverso da Administração (poder voltado para fora).

Ex.: a multa de trânsito é imposta ao motorista, mesmo sem a anuência deste.

- Às vezes: a imperatividade é um atributo que não está presente em todos os atos administrativos (não é universal), pois nem todos a possuem.
Ex.: CNH, que somente é emitida se o particular requerer (o Poder Público não pode obrigar alguém a tirar a CNH).

2.4. Autoexecutoriedade

Autoexecutoriedade é a qualidade de compelir materialmente o administrado, independentemente de ordem judicial.

Significa que a Administração Pública (Poder Executivo) pode impor/executar as suas decisões sem necessitar de provimento judicial (Poder Judiciário).

Ex1: um fiscal da vigilância sanitária (servidor público do Poder Executivo) pode apreender carnes estragadas e ainda interditar o açougue que as vendia, podendo, inclusive, requisitar força policial para lhe auxiliar caso haja resistência por parte do particular (proprietário do açougue). E tudo isso de forma administrativa, ou seja, sem a necessidade de uma ação judicial ou de qualquer autorização do Poder Judiciário.

Ex2: o Poder Executivo pode embargar uma obra (construção de uma casa) e até mesmo demoli-la, o que fará, mais uma vez, sem necessidade de autorização judicial.

a) Autoexecutoriedade = executoriedade + exigibilidade: a autoexecutoriedade decorre da junção de duas outras características dos atos administrativos, quais sejam, a executoriedade e a exigibilidade:

- Executoriedade: a executoriedade são meios diretos de coerção.

Ex.: apreensão de mercadorias.

- Exigibilidade: já a exigibilidade são meios indiretos de coerção.

Ex.: só se consegue obter o licenciamento do veículo se o mesmo não possui multas pendentes, ou seja, a necessidade de se obter o licenciamento anual é um meio indireto de coagir o proprietário a pagar as multas pendentes.

- Às vezes: a autoexecutoriedade não é universal, pois nem todos os atos administrativos a possuem; ou seja, a autoexecutoriedade "às vezes" está presente nos atos administrativos.

O exemplo mais comum são as multas e todos os atos administrativos que imputem débito: a multa pode ser imposta (imperatividade) ao particular sem necessidade de anuência deste nem de autorização judicial (Poder Judiciário); mas se o particular não pagá-la voluntariamente, a Administração Pública (Poder Executivo) deverá ajuizar uma ação judicial perante o Poder Judiciário (execução fiscal) para a sua cobrança – a Administração não pode apropriar-se de bens do particular para satisfazer seu crédito (aqui precisa do Poder Judiciário).

→ **"Sempre"** e **"Às vezes"**

- os atributos iniciados com consoantes **Sempre** estão presentes, ou seja, todos os atos administrativos os possuem: **P**resunção de legitimidade e veracidade e **T**ipicidade; e
- os atributos iniciados com vogais **Às vezes** (nem sempre) estão presentes nos atos administrativos: **A**utoexecutoriedade e **I**mperatividade.

3. ELEMENTOS

a) Requisitos de validade: elementos são os requisitos de validade para que o ato administrativo seja praticado: se algum deles não for observado, o ato será inválido – ilegal, nulo: deverá ser anulado porque não observou a lei.

b) Nulidade: se qualquer elemento não for preenchido, o ato administrativo será inválido, ou seja, será ilegal, pois será um ato que desrespeita a lei.

c) Efeito "ex tunc": como consequência, esse ato administrativo, por ser ilegal, deve ser anulado; e a anulação sempre gera efeitos *ex tunc* (retroativos).

d) Executivo ou Judiciário: como se trata de nulidade (ilegalidade), ela pode ser declarada pela própria Administração Pública (Poder Executivo, através da autotutela administrativa) e pelo Poder Judiciário (por meio de ação judicial proposta pelo lesado).

e) Quais são? Apesar de tratar sobre a ação popular, foi a Lei Nacional n.º 4.717/1965 que consagrou os elementos do ato administrativo (art. 2º).

Lei Nacional n.º 4.717/1965

Art. 2º São nulos os atos lesivos ao patrimônio das entidades mencionadas no artigo anterior, nos casos de:

- a) incompetência;
- b) vício de forma;
- c) ilegalidade do objeto;
- d) inexistência dos motivos;
- e) desvio de finalidade.

Parágrafo único. Para a conceituação dos casos de nulidade observar-se-ão as seguintes normas:

- a) a incompetência fica caracterizada quando o ato não se incluir nas atribuições legais do agente que o praticou;
- b) o vício de forma consiste na omissão ou na observância incompleta ou irregular de formalidades indispensáveis à existência ou seriedade do ato;
- c) a ilegalidade do objeto ocorre quando o resultado do ato importa em violação de lei, regulamento ou outro ato normativo;
- d) a inexistência dos motivos se verifica quando a matéria de fato ou de direito, em que se fundamenta o ato, é materialmente inexistente ou juridicamente inadequada ao resultado obtido;
- e) o desvio de finalidade se verifica quando o agente pratica o ato visando a fim diverso daquele previsto, explícita ou implicitamente, na regra de competência.

→ "CO.FI.FO.MO.OB": o mnemônico utilizado para lembrar os cinco elementos do ato administrativo é o "co.fi.fo.mo.ob":

- **CO**mpetência (agente competente);
- **FI**nalidade (intenção);
- **FO**rma (exteriorização);
- **MO**tivo (situação de fato e de Direito);
- **OB**jeto (ato administrativo em si).

3.1. Competência

a) Conceito: a competência diz respeito a quem tem o poder legal de praticar o ato administrativo, ou seja, é a previsão de quem será o sujeito competente para praticar o ato. As normas jurídicas sempre dirão quem é o sujeito competente (nunca se presume).

b) Características: a competência possui as seguintes características:

- Lei (norma jurídica): a competência sempre decorre da lei, ou seja, é sempre a lei quem dirá quem é o agente (sujeito) competente para a prática do ato.

- Imprescritível: significa que o não exercício da competência, mesmo que por um longo período de tempo, não a extingue.

Ou seja, o sujeito (agente) competente continua sendo competente mesmo que não tenha exercido a competência por um longo período de tempo.

- Irrenunciável: quer dizer que o agente competente não pode renunciar a competência que lhe é dada pela norma jurídica.

Não vale a vontade pessoal, mas sim a vontade da norma.

- Imodificável: a competência não pode ser modificada pela vontade do agente.

Somente as normas jurídicas podem modificar a competência.

- Intransferível (titularidade): a titularidade da competência não pode ser transferida para outrem.

Mas o exercício da competência pode sim ser transferido, o que se faz por meio de delegação.

- Delegável (exercício): delegação é a possibilidade de o agente competente transferir o exercício da competência para outrem (veremos a delegação logo abaixo).

- Avocável (exercício): avocação é a possibilidade de puxar para si o exercício da competência, ou seja, o sujeito chama para si a competência de exercer o ato administrativo que é de titularidade de um subordinado seu.

Portanto, a avocação é o contrário da delegação (também veremos abaixo).

c) Delegação (artigos 12-14, Lei Federal n.º 9.784/1999): a delegação e a avocação de competência têm a ver com o seu exercício e não sua titularidade, pois a titularidade, como visto acima, é sempre intransferível.

Delegar é transferir temporariamente o exercício da competência para outrem (empréstimo para outrem).

A delegação possui as seguintes características:

- Subordinado ou não: a delegação do exercício da competência pode ocorrer para um agente ou órgão subordinado ou superior ao delegante.

Ou seja, pode-se delegar para quem está abaixo ou acima na hierarquia administrativa.

- Revogável a qualquer tempo: a autoridade que delegou o exercício da sua competência para outrem pode revogar a delegação a qualquer tempo.

- Vedação "No.R.Ex": mas nem todo ato administrativo pode ter o exercício delegado; é vedado delegar o exercício da competência dos seguintes atos administrativos:

- atos Normativos;
- decisão de Recursos administrativos; e
- atos de competência Exclusiva.

Lei Federal n.º 9.784/1999

Art. 12. Um órgão administrativo e seu titular poderão, se não houver impedimento legal, delegar parte da sua competência a outros órgãos ou titulares, ainda que estes não lhe sejam hierarquicamente subordinados, quando for conveniente, em razão de circunstâncias de índole técnica, social, econômica, jurídica ou territorial.

Parágrafo único. O disposto no *caput* deste artigo aplica-se à delegação de competência dos órgãos colegiados aos respectivos presidentes.

Art. 13. Não podem ser objeto de delegação:

- I - a edição de atos de caráter normativo;
- II - a decisão de recursos administrativos;
- III - as matérias de competência exclusiva do órgão ou autoridade.

Art. 14. O ato de delegação e sua revogação deverão ser publicados no meio oficial.

§ 1º O ato de delegação especificará as matérias e poderes transferidos, os limites da atuação do delegado, a duração e os objetivos da delegação e o recurso cabível, podendo conter ressalva de exercício da atribuição delegada.

§ 2º O ato de delegação é revogável a qualquer tempo pela autoridade delegante.

§ 3º As decisões adotadas por delegação devem mencionar explicitamente esta qualidade e considerar-se-ão editadas pelo delegado.

d) Avocação (art. 15, Lei Federal n.º 9.784/1999): a delegação e a avocação de competência têm a ver com o seu exercício e não sua titularidade, pois a titularidade é sempre intransferível.

Avocar é chamar para si funções originariamente atribuídas a um subordinado, ou seja, de alguém inferior na hierarquia administrativa.

A avocação possui as seguintes características:

- Somente subordinado: a avocação do exercício da competência somente pode ocorrer quando o agente ou órgão for hierarquicamente subordinado.

Portanto, somente é possível chamar para si o exercício da competência de quem esteja abaixo na pirâmide hierárquica.

- Vedação "Ex": nem todo ato administrativo pode ter o exercício avocado; é vedado avocar o exercício da competência dos seguintes atos administrativos:

- atos de competência Exclusiva do subordinado.

Lei Federal n.º 9.784/1999

Art. 15. Será permitida, em caráter excepcional e por motivos relevantes devidamente justificados, a avocação temporária de competência atribuída a órgão hierarquicamente inferior.

e) Vício de competência = excesso de poder: o excesso de poder, que configura um vício de competência, ocorre em duas situações:

- Falta de competência: quando o agente público não possui competência para praticar o ato administrativo.

Ex.: um fiscal da vigilância sanitária não tem competência para lavrar uma multa de trânsito. Se o fizer, esse ato administrativo (a multa) é nula por falta de competência (vício de competência).

- Excesso de competência: ocorre quando o agente público exorbita (exagera) na utilização da competência que possui.

Ex.: um policial possui competência para multar e determinar o guinchamento do veículo se o motorista estiver realizando manobras perigosas (art. 175, CTB); mas não o CTB não permite guinchar o veículo pelo fato de o motorista não estar usando o cinto de segurança (o motorista será multado; mas basta que coloque o cinto, que sairá guiando seu veículo: art. 167, CTB) – nesta situação, se o policial determinar que o veículo seja guinchado, estará agindo com excesso de competência.

Código de Trânsito Brasileiro

Art. 167. Deixar o condutor ou passageiro de usar o cinto de segurança, conforme previsto no art. 65:

Infração - grave;

Penalidade - multa;

Medida administrativa - retenção do veículo até colocação do cinto pelo infrator.

Art. 175. Utilizar-se de veículo para demonstrar ou exibir manobra perigosa, mediante arrancada brusca, derrapagem ou frenagem com deslizamento ou arrastamento de pneus:

Infração - gravíssima;

Penalidade - multa (dez vezes), suspensão do direito de dirigir e apreensão do veículo;

Medida administrativa - recolhimento do documento de habilitação e remoção do veículo.

Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista no caput em caso de reincidência no período de 12 (doze) meses da infração anterior.

→ Abuso de poder: abuso de poder é o gênero do qual decorrem duas espécies:

- *Excesso de poder* = excesso de competência (vício de competência); e

- *Desvio de poder* = desvio de finalidade (vício de finalidade), que veremos abaixo.

f) Agente putativo ou funcionário de fato: o agente putativo ou funcionário de fato é a pessoa que está investida de forma irregular no cargo público.

Ex.: pessoa que toma posse em cargo público efetivo sem ter prestado concurso público, ou cujo concurso vem a ser anulado.

- Ato nulo (regra): como não poderia deixar de ser, os atos administrativos praticados pelo agente putativo ou funcionário de fato são nulos (inválidos), pois não estão em conformidade com a lei, uma vez que não está presente o elemento competência.

É que o agente putativo ou funcionário de fato não possui competência para praticar atos administrativos, uma vez que, na realidade, nem sequer é um agente público.

- Terceiro de boa-fé (exceção): mas os atos administrativos praticados pelo agente putativo ou funcionário de fato não são inválidos em relação ao terceiro de boa-fé (esse terceiro é um particular, um administrado).

Ex.: licença para construir.

3.2. Finalidade

a) Conceito: a finalidade é a intenção, aquilo que motiva o agente a praticar o ato administrativo.

Ela é vista tanto em sentido amplo (busca do interesse público) quanto em sentido estrito (busca do fim especificado na norma jurídica).

b) Vício de finalidade = desvio de poder: o desvio de poder, que configura um vício de finalidade, ocorre quando o agente público pratica o ato administrativo sem buscar o interesse público ou o fim especificado na norma jurídica.

Ex.: segundo consta do inc. I do único do art. 36 da Lei Federal n.º 8.112/1990, a remoção de ofício do servidor público sempre deve ocorrer no interesse da Administração, o que significa que deve ocorrer em virtude da necessidade do serviço público (essa é a finalidade especificada na norma jurídica). Agora, se um servidor for removido por sua chefia e ficar comprovado que essa remoção ocorreu como uma forma de puni-lo ou em decorrência de alguma perseguição pessoal, o ato será nulo e o servidor terá direito de retornar ao local de origem.

Lei Federal n.º 8.112/1990

Art. 36. Remoção é o deslocamento do servidor, a pedido ou de ofício, no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede.

Parágrafo único. Para fins do disposto neste artigo, entende-se por modalidades de remoção:

I - de ofício, no interesse da Administração;

II - ...

→ Abuso de poder: abuso de poder é o gênero do qual decorrem duas espécies:

- Excesso de poder = excesso de competência (vício de competência), visto acima; e
- Desvio de poder = desvio de finalidade (vício de finalidade).

3.3. Motivo

a) Conceito: o elemento motivo é a situação de fato e o fundamento jurídico (fato + tipicidade) que autorizam ou impõem à Administração Pública a prática do ato administrativo.

Ou seja, são os fatos da vida real (situação de fato) que se amoldam a uma determinada conduta abstrata descrita na norma jurídica (situação de Direito, tipicidade).

Ex1: se o servidor público não comparecer injustificadamente ao trabalho por mais de 30 dias (fato), restará configurado o abandono do cargo público e ele será demitido (Direito), conforme consta do art. 138 da Lei Federal n.º 8.112/1990.

Ex2: uma construção irregular (fato) ensejará a edição de um ato administrativo de embargo ou até mesmo de demolição (Direito) da obra, pois é esta a consequência que consta das normas jurídicas.

Lei Federal n.º 8.112/1990

Art. 138. Configura abandono de cargo a ausência intencional do servidor ao serviço por mais de trinta dias consecutivos.

b) Teoria dos motivos determinantes: a teoria dos motivos determinantes ensina que a situação de fato (fato da vida real) que serviu de suporte para a decisão íntegra a validade do ato administrativo.

Dito de outro modo, a situação de fato alegada para a prática do ato administrativo deve ser verdadeira; se for falsa, o ato será inválido (ilegal, nulo).

Essa teoria torna-se importante para as situações em que a própria lei dispensa a apresentação de um fato para a prática do ato administrativo.

O exemplo sempre utilizado é a exoneração de servidor público ocupante de cargo exclusivamente em comissão, que a norma jurídica menciona ser "[...] de livre nomeação e exoneração" (art. 37, II, parte final, CF).

Ou seja, se a chefia quer exonerar um servidor ocupante de cargo em comissão, não precisa expor o motivo da exoneração (pois é um cargo de livre nomeação e exoneração): basta publicar uma portaria de exoneração e estará tudo certo (o ato administrativo será válido).

Agora, digamos que a chefia desse servidor resolve dispensá-lo e, na portaria, menciona que a exoneração está ocorrendo porque ele falta regularmente ao serviço (apesar de ser desnecessário, motivou o ato); nessa situação, se o servidor provar que essa situação de fato não é verdadeira, ou seja, que é assíduo ao trabalho, a exoneração será ilegal (inválida) em decorrência da teoria dos motivos determinantes.

Vale dizer, a exoneração será nula porque a situação de fato (motivo) alegada para a prática do ato administrativo (exoneração) não é verdadeira.

Obs.: claro que, nesse exemplo, se esse servidor retornar ao trabalho em virtude de ter conseguido anular a portaria, no mesmo dia do retorno ele será novamente exonerado, mas agora certamente a chefia o fará da forma "correta", sem apresentar qualquer motivo para a prática do ato administrativo de exoneração.

Constituição Federal

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

3.4. Forma

a) Conceito: a forma diz respeito ao modo de exteriorização do ato administrativo, observando-se o procedimento previsto na norma jurídica.

O elemento forma é a motivação que leva à prática do ato, devendo a Administração Pública explicar por escrito as razões que levaram à prática do ato, ou seja, “colocar no papel” o elemento motivo (fato+tipicidade).

b) Motivação = exteriorização dos motivos: o elemento forma diz respeito à exteriorização (motivação) dos motivos (elemento motivo: fato+tipicidade) pelos quais se está praticando o ato administrativo.

Como mencionado acima, a forma é colocar no papel o elemento motivo (fato+tipicidade).

Cuidado para não confundir o elemento motivo (acima visto) com a motivação (esta é apenas um dos requisitos do elemento forma).

Ex.: a forma de apurar e aplicar penalidades aos servidores públicos que cometem infrações administrativas é a sindicância ou o PAD (exteriorização), conforme consta do art. 143 da Lei Federal n.º 8.112/1990.

Na sindicância ou PAD a Administração Pública deverá descrever o fato que se amolda a uma determinada norma jurídica (elemento motivo: fato+tipicidade), dizendo o porquê (motivação) de estar aplicando aquela penalidade ao servidor público.

Portanto, se alguma penalidade for aplicada sem que tenha sido instaurada uma sindicância ou um PAD (elemento forma) e sem que tenha havido a descrição (motivação) da situação de fato e do fundamento jurídico (elemento motivo) que justificam a aplicação da mesma, estará desrespeitado o elemento forma do ato administrativo e a consequência será a nulidade da penalidade aplicada ao servidor.

Lei Federal n.º 8.112/1990

Art. 143. A autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante sindicância ou processo administrativo disciplinar, assegurada ao acusado ampla defesa.

Lei Federal n.º 9.784/1999

Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, quando:

- I - neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses;
- II - imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções;
- III - decidam processos administrativos de concurso ou seleção pública;
- IV - dispensem ou declarem a inexigibilidade de processo licitatório;
- V - decidam recursos administrativos;
- VI - decorram de reexame de ofício;
- VII - deixem de aplicar jurisprudência firmada sobre a questão ou discrepem de pareceres, laudos, propostas e relatórios oficiais;
- VIII - importem anulação, revogação, suspensão ou convalidação de ato administrativo.

§ 1º A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato.

§ 2º Na solução de vários assuntos da mesma natureza, pode ser utilizado meio mecânico que reproduza os fundamentos das decisões, desde que não prejudique direito ou garantia dos interessados.

§ 3º A motivação das decisões de órgãos colegiados e comissões ou de decisões orais constará da respectiva ata ou de termo escrito.

→ **Motivo ≠ Motivação:** cuidado para não confundir o elemento motivo com a motivação (esta é apenas um dos requisitos do elemento forma).

- **Elemento motivo:** o motivo é algo estático (fato) que está previsto na lei (tipicidade);

- *Motivação (elemento forma)*: já a motivação é o modo de expor o elemento motivo (exteriorização), ou seja, motivação é colocar o elemento motivo (fato + tipicidade) no papel, é explicar qual o fato ocorrido e qual a norma jurídica aplicável para tal fato.

O cuidado que se deve ter é que a motivação se refere ao elemento forma, e não ao elemento motivo.

Para auxiliar, veja-se o ensinamento da administrativista Maria Sylvia Zanella Di Pietro (*Direito Administrativo*. 27ª ed. São Paulo: Atlas, 2014, ps. 219-220):

Não se confundem motivo e motivação do ato. Motivação é a exposição dos motivos, ou seja, é a demonstração, por escrito, de que os pressupostos de fato realmente existiram. Para punir, a Administração deve demonstrar a prática da infração.

3.5. Objeto

a) Conceito: o objeto é o efeito jurídico imediato produzido pelo ato administrativo.

É o conteúdo material do ato administrativo.

Dito de outra forma, objeto é o próprio ato administrativo.

4. CLASSIFICAÇÃO

Os atos administrativos possuem diversas classificações apontadas pela doutrina administrativista.

Abaixo veremos apenas as mais relevantes.

4.1. Ato Vinculado

a) Conceito: ato vinculado é a manifestação de vontade do Estado que ocorre sem qualquer margem de escolha para o administrador público, pois a lei (norma jurídica) estabelece uma única opção possível.

Dito de outro modo, a norma estabelece o único comportamento possível a ser adotado pela Administração diante de determinada situação de fato.

Ou seja, a “escolha” do administrador público está vinculada ao que a lei determina – escolha entre aspas porque, na verdade, não há escolha possível: a lei determina a única possibilidade a ser adotada.

b) Legalidade (normas jurídicas): o único elemento utilizado para praticar o ato vinculado é a legalidade, ou seja, o Administrador Público vai fazer aquilo que a norma jurídica (lei ou qualquer outra norma jurídica) determina.

Aqui não há o elemento vontade, pois não importa qual é a vontade do Administrador Público, já que ele deverá fazer o que a norma determina.

Relembre-se que a Administração Pública deve respeitar o “LIMPE”, ou seja, os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (art. 37, *caput*, CF).

Constituição Federal

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

I - [...]

c) Obrigado a praticar o ato: além do mais, se os requisitos previstos na lei foram preenchidos, o Poder Público é obrigado a praticar o ato administrativo, ou seja, sequer há “escolha” entre praticar ou não o ato.

Preenchidos os requisitos legais, o ato administrativo obrigatoriamente deve ser praticado e o será nos exatos termos determinados pela lei.

d) Não há opção: se os requisitos legais do ato vinculado foram preenchidos, não há escolha para a Administração Pública (Poder Executivo), que deverá praticar o ato nos exatos termos determinados pela norma.

Abaixo alguns exemplos.

Ex1: na CNH (licença para dirigir), se o candidato fez as aulas teóricas e práticas e foi aprovado nas respectivas provas, a Administração Pública é obrigada a lhe conceder a licença pelo prazo disposto na lei (CNH provisória pelo prazo de um ano).

Ou seja, preenchidos os requisitos legais, a própria lei menciona qual a atitude que deve ser adotada pela Administração, sem qualquer margem de escolha.

Se a CNH não for concedida, o cidadão poderá impetrar mandado de segurança (direito líquido e certo) e o Poder Judiciário, observando que os requisitos legais foram preenchidos, determinará à Administração Pública (Poder Executivo) que conceda a CNH, pois é isso que a lei determina.

Perceba-se que o Poder Judiciário sempre pode controlar a legalidade dos atos administrativos vinculados do Poder Executivo, sem que isso afete a independência dos Poderes (funções estatais), uma vez que “a lei é para todos”, ou seja, evidentemente o Poder Executivo também deve cumprir o que a lei determina.

Ex2: a licença paternidade do servidor público federal é 5 dias, conforme disposto no art. 208 da Lei Federal n.º 8.112/1990. Dessa forma, o Administrador Público não tem opção: o servidor homem que se torna pai tem direito a 5 dias de licença.

Mais uma vez, se a licença não for concedida ou for concedida por um prazo inferior a 5 dias, esse servidor facilmente a conseguirá perante o Poder Judiciário através de mandado de segurança: bastará juntar a certidão de nascimento do filho e demonstrar a negativa da Administração em lhe conceder a licença paternidade.

Lei Federal n.º 8.112/1990

Art. 208. Pelo nascimento ou adoção de filhos, o servidor terá direito à licença-paternidade de 5 (cinco) dias consecutivos.

Ex3: a aposentadoria é outro grande exemplo de ato vinculado, pois se a pessoa cumprir os requisitos legais, o INSS (autarquia do Poder Executivo federal) obrigatoriamente deve conceder-lhe a aposentadoria.

Doutro modo, se um dos requisitos não for atendido, a única opção possível é o indeferimento da aposentadoria.

e) Ato vinculado ilegal: se a Administração Pública (Poder Executivo) praticar um ato vinculado sem respeitar as normas jurídicas, teremos as seguintes consequências – elas serão estudadas no tópico “5.1. Anulação”, ainda neste material:

- Anulação: o ato administrativo praticado em desconformidade com a Lei (normas jurídicas) deve ser anulado – Súmulas 346 e 473 do STF e o art. 53 da Lei Federal n.º 9.784/1999.

- Efeito “ex tunc”: a anulação terá efeitos *ex tunc*, vale dizer, retroativos.

- Executivo e Judiciário: por fim, como se trata de ato administrativo contrário à normas jurídicas, ilegal, a sua anulação pode ser retalizada tanto pela própria Administração Pública (autotutela administrativa) quanto pelo Poder Judiciário.

4.2. Ato Discricionário

a) Conceito: no ato discricionário o Administrador Público possui margem de escolha, possui certa liberdade de atuação, escolhendo qual decisão irá adotar e se irá ou não adotá-la.

Mas essa liberdade de escolha ocorre dentro de limites traçados pelas normas jurídicas.

Ou seja, enquanto no ato administrativo vinculado a lei determina qual é a única atitude possível a ser adotada pela Administração Pública (Poder Executivo), no ato administrativo discricionário a lei dá ao Administrador a possibilidade de praticar ou não o ato administrativo ou, quando obriga a sua prática, fixa limites dentro dos quais a atuação poderá ocorrer.

b) Elementos: o ato discricionário administrativo discricionário possui dois elementos, quais sejam, a legalidade e o mérito:

- ***Legalidade (normas jurídicas):*** o ato administrativo discricionário, assim como o vinculado, também deve ser praticado nos termos da legislação, ou seja, também deve respeitar as normas jurídicas.

Portanto, num primeiro momento, o ato discricionário é igual ao vinculado, pois o Administrador Público sempre deve observar as normas – princípio da legalidade (art. 37, caput, CF).

- ***Mérito administrativo (oportunidade e conveniência, margem de escolha):*** a diferença entre o ato administrativo vinculado e o discricionário é que este possui um plus em relação àquele – esse plus é o mérito, a margem de escolha, a oportunidade e conveniência em praticar o ato.

No ato discricionário, essa margem de escolha pode apresentar-se de vários modos diferentes: há situações em que a norma dará a opção ao Administrador Público (Poder Executivo) para praticar ou não o ato administrativo e outras em que dará a opção de ele escolher entre limites mínimo e máximo:

- ***Praticar ou não o ato:*** aqui o Poder Executivo tem liberdade para praticar o ato administrativo ou não – cabe à Administração Pública decidir se o momento é adequado (oportunidade) e se há interesse público (conveniência) para a prática do ato administrativo.

- ***Limites:*** também há situações em que a norma jurídica determina que o ato administrativo seja praticado, mas dá ao Administrador Público a possibilidade de escolher entre limites mínimo e máximo (margem de escolha) dentro dos quais ele poderá atuar no caso concreto.

c) Limite do mérito administrativo: legalidade (norma jurídica): o primeiro limite que o mérito do ato administrativo discricionário possui é a legalidade, pois são as normas jurídicas que dirão quais os limites mínimo e máximo (margem de escolha) que o Administrador Público possui para fazer sua escolha.

Ex.: para uma série de infrações cometidas por servidores públicos, a lei determina que a penalidade a ser aplicada será a suspensão de 1 a até 90 dias (art. 130, Lei Federal n.º 8.112/1990); portanto, comprovado que o servidor praticou uma infração que deve ser punida com suspensão, sua chefia poderá escolher por quanto dias irá suspendê-lo, mas nunca ultrapassando 90 dias, pois este é o limite máximo dado pela norma. Aqui, se a chefia suspender o servidor por mais de 90 dias, ela feriu o limite da legalidade.

Lei Federal n.º 8.112/1990

Art. 130. A suspensão será aplicada em caso de reincidência das faltas punidas com advertência e de violação das demais proibições que não tipifiquem infração sujeita a penalidade de demissão, não podendo exceder de 90 (noventa) dias.

§ 1º [...]

d) Limite do mérito administrativo: **legitimidade** (razoabilidade e proporcionalidade): o outro limite que o mérito administrativo possui é o da legitimidade, que diz respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, segundo os quais deve haver uma relação de equivalência entre a medida adotada e o objetivo da norma (razoabilidade) e a adoção de meios adequados, necessários e proporcionais para a busca do fim visado pela norma (proporcionalidade).

Ex.: na mesma situação acima, da suspensão do servidor público faltoso, caberá à chefia determinar, com base na razoabilidade e proporcionalidade, o prazo que ele deve ficar suspenso (de 1 a até 90 dias); portanto, a chefia deve verificar a gravidade do fato praticado, quais as consequências advindas do mesmo, se o servidor faltoso se arrependeu... Dessa forma, para uma falta leve e sem grandes consequências, a razoabilidade e a proporcionalidade indicam que a suspensão deve ser por um período próximo do mínimo (e não do máximo).

e) **Desrespeito aos limites do mérito administrativo:** quando a Administração Pública (Poder Executivo) desrespeita os limites do mérito do ato administrativo, as consequências são exatamente as mesmas que temos quando estamos diante de um ato vinculado ilegal, quais sejam:

- Ato nulo: como não foi respeitado a legalidade (norma jurídica) e/ou a legitimidade (razoabilidade e proporcionalidade) na prática do ato administrativo discricionário, o mesmo é ilegal, nulo, e deve ser anulado.

- Efeito ex tunc: a anulação gera efeito *ex tunc*, retroativo (*status quo ante*).

- Quem pode anular? Tanto o Poder Executivo (autotutela administrativa) quanto o Poder Judiciário.

f) **Respeito aos limites do mérito administrativo:** agora, quando a Administração Pública (Poder Executivo) pratica o ato discricionário respeitando todos os dois limites do mérito administrativo – legalidade e legitimidade –, o Poder Judiciário não poderá analisar o ato, já que não há qualquer ilegalidade ou ilegitimidade a ser declarada.

Portanto, quando o ato administrativo discricionário é praticado em conformidade com a legalidade (respeitando a norma jurídica) e com a legitimidade (de forma razoável e proporcional), o Poder Judiciário jamais poderá analisar o ato.

→ Ato discricionário ≠ Ato arbitrário: não confundir ato discricionário com ato arbitrário:

- Ato discricionário: é praticar o ato administrativo dentro dos limites da legalidade (normas jurídicas) e da legitimidade (razoabilidade e proporcionalidade);

- Ato arbitrário: é praticar o ato administrativo fora dos limites da lei, ou seja, aqui o Administrador Público pratica o ato como “bem entender”, sem respeitar o momento ou os limites mínimo e máximo fixados pela lei.

Portanto, podemos ter tanto um ato vinculado que seja arbitrário, quanto um discricionário que seja arbitrário, pois na arbitrariedade ocorre desrespeito à legalidade (o ato administrativo é praticado sem respeitar as leis, as normas jurídicas).

4.3. Quanto aos Destinatários

Diz respeito à possibilidade de identificarem-se os destinatários do ato administrativo.

a) Ato geral: é o ato administrativo dirigido a destinatários incertos ou indeterminados – os atos gerais são classificados como atos normativos.

O ato geral é parecido com a lei, pois ambos se dirigem a destinatários indeterminados.

Portanto, o ato administrativo geral é aquele que atinge uma quantidade indeterminada de pessoas: atinge todas as pessoas que se encontram naquela mesma situação fática regulada pelo ato administrativo.

Ex1: os decretos do Governo do Estado de SC que vedavam uma série de atividades em decorrência do Covid-19.

Ex2: uma instrução normativa municipal que explicita quais atividades comerciais podem abrir aos domingos.

b) Ato individual: já o ato administrativo individual é aquele dirigido a destinatários certos e determinados, podendo tratar-se de mais de uma pessoa.

Cuidado: ato administrativo individual não significa que ele seja dirigido a um único destinatário, mas sim que os seus destinatários são certos e determinados (mesmo que coletivamente).

Ex.: uma portaria de nomeação dos quatro primeiros colocados num concurso público – trata-se de um ato individual, pois os quatro destinatários são pessoas certas e determinadas que estarão identificadas na portaria de nomeação.

4.4. Quanto à Formação da Vontade

Diz respeito às manifestações de vontades necessárias para que o ato administrativo se materialize.

a) Ato simples: ato administrativo simples é aquele que depende da manifestação de vontade de um único órgão, que emite um único ato.

Mas cuidado, pois o órgão que emite o ato pode ser unipessoal ou colegiado.

- Ato simples singular: é o ato emitido por um órgão unipessoal (é como se fosse uma sentença proferida por um juiz de primeiro grau).

Ex.: portaria de aplicação de uma penalidade ao servidor público pelo seu superior hierárquico, que é uma pessoa apenas.

- Ato simples colegiado: é o ato emitido por um órgão colegiado, ou seja, por um órgão composto por mais de uma pessoa (é como se fosse um acórdão proferido por uma turma de Tribunal).

Ex.: resolução emitida por um Conselho Municipal, o qual é composto por vários integrantes.

Portanto, no ato simples (seja singular ou colegiado) temos:

- um órgão;
- um ato.

b) Ato complexo: no ato administrativo complexo temos a manifestação de vontade de dois ou mais órgãos, que se unem para praticar um único ato.

Aqui, quando o primeiro órgão se manifesta, o ato administrativo já é eficaz, já é válido, já produz efeitos; mas o ato somente se torna perfeito quando o segundo (ou terceiro...) órgão manifestar a sua vontade.

Ex1: a aposentadoria dos servidores públicos é concedida pelo órgão previdenciário (a partir dessa concessão o servidor já se aposenta: para de trabalhar e passa a receber os proventos de aposentadoria), mas depende da manifestação posterior do Tribunal de Contas para que se torne um ato perfeito (o Tribunal de Contas deve aprovar e registrar o ato: art. 71, III, CF).

Se o TC não concordar com a aposentadoria e não realizar o registro do ato, o servidor terá de voltar ao trabalho, pois o ato administrativo não se perfectibilizou – faltou a anuência de um dos órgãos envolvidos na prática do ato administrativo.

Ex2: uma portaria interministerial, que é uma portaria emitida por dois ou mais Ministérios em conjunto, também é exemplo de ato administrativo complexo.

Portanto, no ato complexo temos (macete: complexo = sexo, duas ou mais pessoas que praticam um único ato):

- dois ou mais órgãos;
- um único ato.

Constituição Federal

Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete:

III - apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal, a qualquer título, na administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão, bem como a das concessões de aposentadorias, reformas e pensões, ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessório;

c) Ato composto: no ato composto também temos a manifestação de vontade de dois ou mais órgãos, mas aqui ocorre a prática de dois ou mais atos, sendo que o ato administrativo somente se torna eficaz depois que todos os órgãos envolvidos manifestam sua vontade (relembre-se que no ato complexo o ato administrativo já é eficaz a partir do momento em que o primeiro órgão manifesta sua vontade).

Portanto, aqui no ato administrativo composto temos dois ou mais atos: o ato principal, que é praticado pelo primeiro órgão (este é o ato administrativo propriamente dito) e os atos acessórios, que são praticados pelo segundo, terceiro... órgãos (estes são apenas instrumentais ou acessórios, mas necessários para que o ato administrativo se perfectibilize).

Ex.: os pareceres jurídicos emitidos por Procuradores públicos, via de regra, não possuem caráter vinculativo; dessa forma, a conclusão apontada no parecer jurídico emitido pelo Procurador somente se torna um ato administrativo quando a autoridade competente a homologa.

Portanto, no ato composto temos:

- dois ou mais órgãos;
- dois ou mais atos.

4.5. Quanto à Perfeição, Validade e Eficácia

Quanto à perfeição, validade e eficácia, os atos administrativos podem ser perfeitos, válidos e eficazes.

a) Ato perfeito: ato perfeito é o ato administrativo que completou o seu ciclo de formação, ou seja, todas as etapas do seu processo de elaboração foram concluídas.

- *Ato imperfeito:* é o ato administrativo que não completou todas as etapas do seu ciclo de formação.

b) Ato válido: é o ato administrativo que está em conformidade com a legalidade, ou seja, em total conformidade com o ordenamento jurídico (normas jurídicas).

- *Ato inválido:* é um ato ilegal, desconforme com a lei (ato nulo).

c) Ato eficaz: por fim, ato administrativo eficaz é aquele que está apto, pronto para a produção de efeitos jurídicos.

- *Ato ineficaz:* é o ato administrativo que não produz efeitos.

4.6. Quanto à Imperatividade

Quanto à imperatividade, os atos administrativos podem ser de império ou negociais.

a) Ato de império (direito público) (ato administrativo): aqui estamos diante de ato administrativo propriamente dito.

O ato de império é aquele imposto coercitivamente ao particular pela Administração Pública, independentemente do seu consentimento.

Portanto, o ato de império é praticado pelo Poder Público mesmo que o particular não concorde com ele.

Os atos de império decorrem diretamente do princípio da supremacia do interesse público (interesse da coletividade) sobre o interesse particular (interesse egoístico do indivíduo).

Os atos administrativos sempre são atos de império.

Ex1: se o Poder Público quer passar a ser proprietário de um determinado imóvel particular para nele instalar uma escola, as normas de direito público colocam à disposição da Administração o instituto da desapropriação, por meio do qual o Poder Público adquirirá a propriedade do imóvel mesmo sem a anuência do particular.

Ex2: a multa de trânsito é imposta ao motorista mesmo que ele não concorde; o mesmo ocorre com a interdição de atividade, a apreensão de mercadorias...

b) Ato negocial ou de gestão (direito privado) (ato da Administração): aqui estamos diante de ato da Administração, e não ato administrativo – trata-se dos atos jurídicos de direito privado estudados no Tópico "1.1. Atos Administrativos ≠ Atos da Administração", deste material.

Para reforçar: o ato negocial ou de gestão nem sequer é um ato administrativo (que é o objeto do nosso estudo neste material).

Os atos de gestão ou negociais resultam do consentimento de ambas as partes – Administração e particular –, ou seja, sem que a Administração possa impor sua vontade ao particular.

Dessa forma, o ato de gestão somente será praticado pela Administração Pública se o particular concordar.

Ex1: no exemplo 1 acima, se a Administração quer apenas alugar aquele imóvel particular para instalar o posto de saúde, não há previsão legal de que possa impor essa sua vontade ao particular – isso apenas ocorre para a aquisição do bem (por meio da desapropriação), mas não para sua locação.

Portanto, não há norma de direito público que garanta supremacia para a Administração quando ela quiser alugar um imóvel; sendo assim, deverão ser observadas as normas de direito privado – *in casu*, incidirá a Lei de Locações (n.º 8.245/1991). E no âmbito do direito privado, vigora o consenso: o Poder Público e o particular terão de chegar a um acordo de vontades sobre a locação do imóvel (atuarão em igualdade de condições: ato da administração). Se o particular não quiser alugar o imóvel, não há o que o Poder Público possa fazer.

Mas se a Administração entender que deve desapropriar aquele bem – e tornar-se proprietária do mesmo –, ela o fará mesmo contra a vontade do particular (ato administrativo), pois o direito público prevê o instituto da desapropriação.

Ex2: a investidura de candidato aprovado em concurso público também depende da aceitação do particular – a Administração faz a nomeação do candidato aprovado, mas ele somente tomará posse no cargo se quiser (ato da administração).

5. EXTINÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS

Há seis formas de extinção dos atos administrativos:

- *Anulação;*
- *Revogação;*
- *Caducidade;*
- *Contraposição;*
- *Cassação;* e
- *Renúncia.*

5.1. Anulação

a) Conceito: a anulação dos atos administrativos ocorre quando eles foram ilegais, ou seja, contrários às normas jurídicas.

b) Vício de legalidade: a anulação é o desfazimento do ato administrativo em virtude de sua ilegalidade, vale dizer, quando o ato administrativo possui um vício em sua legalidade, quando ele está infringindo alguma norma jurídica.

c) Defeito insanável: o vício de legalidade (a ilegalidade) é um vício insanável, ou seja, impossível convalidar, de ser tornado válido, de salvar.

Dessa forma, quando um ato administrativo é ilegal, ele não tem salvação: deve ser anulado (não é possível aplicar o art. 55 da Lei Nacional n.º 9.784/1999).

Lei Federal n.º 9.784/1999

Art. 55. Em decisão na qual se evidencie não acarretarem lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros, os atos que apresentarem defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela própria Administração.

d) Efeito "ex tunc": a anulação gera efeito *ex tunc*, que é aquele no qual as coisas voltam ao *status quo ante*, ou seja, as coisas devem retornar ao estado em que se encontravam antes da prática do ato.

Portanto, a anulação produz efeitos retroativos.

e) Quem pode anular? A anulação do ato administrativo pode ocorrer tanto pelo próprio Poder Executivo (Administração Pública), que é quem praticou o ato, quanto pelo Poder Judiciário.

- Poder Executivo que praticou o ato ilegal = autotutela administrativa: o Poder Público (Poder Executivo) tem o dever de anular o ato administrativo ilegal, conforme consta das Súmulas 346 e 473 do STF e do art. 53 da Lei Federal n.º 9.784/1999.

Esse dever decorre do princípio da autotutela administrativa, segundo o qual Administração Pública possui o poder-dever de controlar os próprios atos, anulando-os quando forem ilegais.

Portanto, a Administração Pública (Poder Executivo) não precisa recorrer ao Poder Judiciário para corrigir os seus atos, devendo fazê-lo diretamente.

Apesar de as Súmulas 346 e 473 do STF mencionarem “pode”, a anulação é um “dever” da Administração Pública, conforme consta do art. 53, primeira parte, da Lei Federal n.º 9.784/1999 (as Súmulas são, respectivamente, de 1963 e 1969; a Lei é de 1999).

- Poder Judiciário: agora, se o Poder Executivo que praticou o ato ilegal não anular o mesmo, a pessoa lesada com a sua prática pode propor uma ação judicial perante o Poder Judiciário para que este anule o ato (art. 5º, XXXV, CF).

Trata-se de hipótese em que o Poder Judiciário controlará o ato administrativo praticado pelo Poder Executivo: teoria dos freios e contrapesos.

O Poder Judiciário pode analisar o ato administrativo nulo porque ele deve ser praticado nos exatos termos determinados pela lei (norma jurídica), sendo que a função típica do Poder Judiciário é julgar os conflitos de interesse com base na legalidade.

Portanto, nesse caso não há invasão do Poder Judiciário nas atribuições do Poder Executivo, pois a função típica do Poder Judiciário é “dar a última palavra” em termos de legalidade, exercendo a jurisdição – julgar os conflitos de interesse com definitividade, produzindo a coisa julgada.

Se uma norma jurídica foi desrespeitada (não foi observada), o ato administrativo é ilegal e o Poder Judiciário declarará essa ilegalidade, anulando o ato com efeito *ex tunc*.

Mas o Poder Judiciário somente pode anular os atos administrativos (Poder Executivo), nunca revogar – veremos o instituto da revogação abaixo.

Súmulas

S.346/STF. A Administração Pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos.

S.473/STF. A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.

Lei Federal n.º 9.784/1999

Art. 53. A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade, e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos.

Constituição Federal

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;

g) Decadência (art. 54, Lei Nacional n.º 9.784/1999): mas a anulação do ato administrativo ilegal que esteja produzindo efeitos favoráveis ao administrado (particular) somente pode ocorrer se ainda não se perfectibilizou a decadência, que possui prazo quinquenal (prazo de 5 anos).

Então, temos as hipóteses abaixo:

- Prazo decadencial de 5 anos: se o ato administrativo, apesar de ilegal, está produzindo efeito favorável ao destinatário, a Administração Pública (Poder Executivo) tem o prazo de cinco anos para anulá-lo.

Portanto, passados mais de cinco anos da data da prática do ato ilegal, se o mesmo é favorável ao particular, ele não pode mais ser anulado pela Administração Pública.

- Interrupção do prazo decadencial (§§ 1º e 2º do art. 54 da Lei Nacional n.º 9.784/1999): o prazo decadencial considera-se interrompido quando a Administração Pública adotar qualquer medida que importe em impugnação à validade do ato.

- Prazo Perpétuo: o ato administrativo que esteja produzindo efeito desfavorável ao destinatário pode (deve) ser anulado pela Administração Pública a qualquer momento.

Aqui não existe prazo para anular porque, na prática, a anulação do ato administrativo será benéfica ao destinatário – pois o ato estava produzindo efeito desfavorável a ele.

- Prazo Perpétuo (má-fé do destinatário): por fim, quando o ato administrativo foi praticado em virtude da má-fé do destinatário, a Administração Pública também poderá (deverá) anulá-lo mesmo que se tenham passado mais de cinco anos da data em que foi praticado.

Ex.: o INSS (autarquia do Poder Executivo da União) concede pensão por morte para alguém com base numa certidão de casamento falsificada por essa pessoa, na qual ela constava como cônjuge do segurado falecido.

- Executivo e Judiciário: o prazo decadencial aplica-se tanto para a autotutela administrativa (realizada pelo próprio Poder Executivo), quanto para a ação judicial (perante o Poder Judiciário).

Ou seja, tanto o Executivo quanto o Judiciário somente podem anular o ato administrativo se a decadência não se perfectibilizou.

Lei Federal n.º 9.784/1999

Art. 54. O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé.

§ 1º No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo de decadência contar-se-á da percepção do primeiro pagamento.

§ 2º Considera-se exercício do direito de anular qualquer medida de autoridade administrativa que importe impugnação à validade do ato.

5.2. Revogação

a) Conceito: a revogação dos atos administrativos ocorre por oportunidade e conveniência da Administração Pública (Poder Executivo).

Essa oportunidade e conveniência chama-se mérito administrativo.

b) Oportunidade e conveniência: a revogação é o desfazimento do ato administrativo discricionário e válido, por razão de oportunidade (momento) e conveniência (interesse público) da Administração Pública, ou seja, por questões de mérito administrativo.

Dito de outra forma: na revogação temos um ato administrativo que está em conformidade com as normas jurídicas (o ato não é ilegal), mas a Administração Pública entende que deve retirar o ato do mundo jurídico a partir de dado momento.

Portanto, como o ato administrativo é legal (não possui vício de legalidade), ele pode ser apenas revogado – se fosse ilegal, obrigatoriamente deveria ser anulado.

c) Válido e eficaz: desse modo, na revogação temos um ato administrativo que é válido (é legal, está em conformidade com as normas jurídicas) e eficaz (está produzindo efeitos normalmente); mas, por razão de oportunidade e conveniência (mérito administrativo), a Administração Pública entende que é melhor retirá-lo do mundo jurídico (revogar).

d) Direito adquirido (parte final da Súmula 473/STF e também do art. 53 da Lei Nacional n.º 9.784/1999): mas quando o ato administrativo discricionário já gerou direito adquirido ao particular, ele não pode mais ser revogado pela Administração Pública (Poder Executivo), pois já produziu todos os seus efeitos.

Portanto, como já produziu os efeitos, sequer há razão para retirá-lo do mundo jurídico.

Súmula

S.473/STF. A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.

Lei Federal n.º 9.784/1999

Art. 53. A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade, e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos.

e) Poder Judiciário (não): como mencionado no tópico anterior, da anulação do ato administrativo, o Poder Judiciário somente pode anular um ato administrativo, pois a anulação ocorre sempre que um ato é ilegal (desrespeita alguma norma jurídica).

O Judiciário jamais pode revogar um ato administrativo, pois a revogação diz respeito ao mérito (oportunidade e conveniência) administrativo.

Dito de outra forma, somente a Administração Pública (Poder Executivo) sabe se é oportuno e conveniente revogar um ato administrativo, não podendo o Poder Judiciário imiscuir-se nessa questão.

Se o Poder Judiciário revogasse um ato administrativo, ele estaria invadindo a esfera de competência do Poder Executivo (invasão de Poderes).

5.3. Diferença entre Anulação e Revogação

Abaixo um quadro com as diferenças entre os institutos da anulação e da revogação.

	Anulação	Revogação
Razão	Ilegalidade	Mérito administrativo
Tipo de ato	Ato vinculado + discricionário	Somente ato discricionário
Efeito	<i>Ex tunc</i> (retroativo)	<i>Ex nunc</i> (não retroativo)
Quem pode	Executivo + Judiciário	Executivo
Direito adquirido*	Sempre deve anular	Não pode mais revogar
Convalidar**	Não pode	Pode
Dever de indenizar	Em regra não há	

**Direito adquirido*: quando o ato já houver gerado direito adquirido ao particular, ele não pode mais ser revogado (parte final da Súmula 473/STF e também do art. 53 da Lei Nacional n.º 9.784/1999).

***Convalidar*: o ato administrativo que apresente defeitos sanáveis pode ser convalidado pela Administração Pública (art. 55, Lei Nacional n.º 9.784/1999).

5.4. Caducidade

a) Conceito: na caducidade, o ato administrativo é retirado do mundo jurídico porque sobreveio norma jurídica que o extingue.

É semelhante ao que ocorre com as leis: lei posterior revoga a anterior (art. 2º, § 1º, LINDB).

Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro

Art. 2º [...]

§ 1º A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior.

Ex.: uma nova lei de trânsito passa a exigir a idade de 21 anos para a obtenção da CNH, mencionando que as CNH's de pessoas com menos desta idade estão automaticamente inválidas (caducidade).

5.5. Contraposição

a) Conceito: a contraposição é a emissão de um ato administrativo contraposto ao anterior. Portanto, trata-se de um ato posterior e contrário ao ato inicial.

Ex.: o candidato aprovado em concurso público é nomeado e toma posse no cargo; posteriormente, essa pessoa se exonera do cargo público.

5.6. Renúncia

a) Conceito: renúncia é a extinção do ato administrativo decorrente da manifestação de vontade do próprio beneficiário do ato.

A renúncia sempre ocorre antes da prática do ato; quando é posterior, temos contraposição.

Ex.: o candidato aprovado em concurso público é nomeado, mas manifesta sua renúncia em tomar posse no cargo.

5.7. Cassação

a) Conceito: a cassação ocorre quando o destinatário do ato administrativo deixa de cumprir os requisitos para a manutenção do ato.

Ex.: cassação de CNH, de licença para construir, da licença para o exercício da profissão de advogado pela OAB.

6 QUESTÕES

- 01) ()** O ato administrativo é praticado pelo Poder Público valendo-se das prerrogativas de direito público e da anuência do particular.
- 02) ()** Ato administrativo e ato da Administração são expressões sinônimas.
- 03) ()** O ato administrativo pode ser praticado tanto pela Administração Pública quanto por particulares.
- 04) ()** Os atos administrativos são praticados no âmbito do Poder Executivo, na administração da res publica.
- 05) ()** A presunção de legitimidade ou veracidade dos atos administrativos sempre está presente e qualifica-se como iuris et de iuri, não admitindo prova em contrário.
- 06) ()** A imperatividade significa que os atos administrativos são praticados pela Administração Pública valendo-se do seu poder de império, impondo-se a terceiros sem a necessidade da anuência destes.
- 07) ()** Os meios diretos e indiretos de coerção de que o Poder Público dispõe, decorrem do atributo da autoexecutoriedade dos atos administrativos.
- 08) ()** Presunção de legitimidade e de veracidade, autoexecutoriedade, tipicidade e imperatividade são atributos que estão presentes em todos os atos administrativos.
- 09) ()** São nulos os atos administrativos quando eivados de incompetência, vício de forma, ilegalidade do objeto, inexistência dos motivos ou desvio de finalidade.
- 10) ()** A competência para a prática do ato administrativo pode ser delegada, mas não avocada.
- 11) ()** A delegação de competência somente pode ocorrer para agente subordinado.
- 12) ()** É vedado delegar a prática de atos normativos, atos de competência exclusiva e a decisão de recursos administrativos.
- 13) ()** Os vícios de competência (excesso de poder) e de finalidade (desvio de poder) são espécies do gênero abuso de poder.
- 14) ()** O elemento finalidade, que é a intenção do agente público ao praticar o ato administrativo, representa a busca do interesse público e do fim especificado na norma jurídica.
- 15) ()** A situação de fato que se amolda a uma determinada norma jurídica, configura o elemento motivo do ato administrativo.
- 16) ()** Pela teoria dos motivos determinantes, a situação de fato alegada pelo agente público para a prática do ato administrativo integra a própria validade do ato, de modo que este será nulo se a situação alegada não for verdadeira.
- 17) ()** O elemento forma diz respeito à exteriorização do ato administrativo, que deve respeitar o procedimento previsto na norma legal.

- 18) ()** O objeto é o conteúdo material do ato administrativo, ou seja, seu efeito jurídico imediato.
- 19) ()** Quando o ato administrativo foi praticado em desconformidade com alguma norma jurídica, o mesmo deve ser retirado do mundo jurídico por meio do instituto da revogação, com efeitos prospectivos.
- 20) ()** Com base na autotutela administrativa, a Administração Pública pode tanto anular quanto revogar um ato administrativo praticado.
- 21) ()** Passados cinco anos da data da prática do ato administrativo, ele não pode mais ser revogado.
- 22) ()** Qualquer medida praticada pelo Poder Público que importe em impugnação à validade do ato administrativo, interrompe o prazo decadencial quinquenal para a anulação desse mesmo ato.
- 23) ()** Quando o beneficiário do ato administrativo age de má-fé para que o mesmo seja praticado em seu favor, a Administração Pública poderá anular esse ato a qualquer momento, mesmo ultrapassado o prazo de cinco anos.
- 24) ()** O Poder Judiciário sempre pode anular atos administrativos praticados pelo Poder Executivo, pois a anulação diz respeito à conformidade do ato com as normas jurídicas, sendo atividade típica do Poder Judiciário aplicar as normas ao caso concreto.
- 25) ()** A revogação dos atos administrativos diz respeito à sua oportunidade e conveniência, ou seja, ao mérito administrativo, vale dizer, o ato não afronta as normas legais, razão pela qual somente o próprio Poder Executivo pode revogar o ato praticado por ele próprio.
- 26) ()** Como na revogação o ato administrativo não afronta qualquer norma legal, seus efeitos serão apenas ex nunc, resguardando-se os efeitos jurídicos ocorridos até o momento da revogação.
- 27) ()** Na caducidade, temos a superveniência de norma legal, que extingue o ato administrativo anteriormente praticado, por ser contrário a ele.
- 28) ()** Quando alguém pratica um ato que contradiz o anterior, estamos diante do instituto da contraposição, modalidade de extinção dos atos administrativos.
- 29) ()** A renúncia nada mais é do que a manifestação de vontade da Administração Pública que extingue ato anteriormente praticado por ela própria.
- 30) ()** O ato administrativo vinculado é aquele que leva em conta unicamente a legalidade, ou seja, a conformidade com as normas jurídicas, cabendo ao agente público optar, dentro de uma margem de escolha, pela oportunidade e conveniência em praticar tal ato.
- 31) ()** O mérito administrativo está diretamente ligado ao ato administrativo discricionário.
- 32) ()** Mesmo o mérito administrativo, qualificador do ato discricionário, possui limites, quais sejam, a legalidade, que diz respeito às normas jurídicas, e a legitimidade, informada pela razoabilidade e proporcionalidade.

33) () Atos administrativos sempre decorrem do poder de império da Administração Pública, regida pelo Direito Público, pois, se assim não for, estar-se-á diante de ato negocial, o qual é regido pelas normas de Direito Privado.

34) () Ato administrativo individual é aquele dirigido a destinatário certo e determinado, ou seja, a uma única pessoa.

35) () Quando há a necessidade de manifestação de mais de uma pessoa ou órgão, produzindo mais de um ato, estamos diante de ato administrativo complexo.

36) () Ato administrativo perfeito, válido e eficaz é aquele que, respectivamente, cumpriu todas as etapas, estando apto à produção de efeitos jurídicos e que foi produzido em conformidade com as normas vigentes.

Q207862

Ano: 2007 Banca: VUNESP Órgão: OAB-SP Prova: VUNESP - 2007 - OAB-SP - Exame de Ordem - 2 - Primeira Fase

Sobre os atos administrativos, é incorreto afirmar que:

- () A) constituem declaração do Estado ou de quem lhes faça as vezes.
- () B) sujeitam-se ao regime jurídico administrativo ou de direito público.
- () C) gozam de presunção de legitimidade e veracidade.
- () D) sempre possuem, independentemente de previsão legal expressa, auto-executoriedade.

Q207754

Ano: 2007 Banca: VUNESP Órgão: OAB-SP Prova: VUNESP - 2007 - OAB-SP - Exame de Ordem - 1 - Primeira Fase

Não caracterizam prerrogativas de potestade pública:

- () A) a presunção de legitimidade de seus atos.
- () B) a exigibilidade.
- () C) o interesse público primário.
- () D) a imperatividade.

Q299619

Ano: 2006 Banca: CESPE Órgão: OAB Prova: CESPE - 2006 - OAB - Exame de Ordem - 1 - Primeira Fase

Os atos administrativos possuem atributos que os diferenciam dos atos privados. Assinale a opção que não configura atributo exclusivo do ato administrativo.

- () A) presunção de legitimidade.
- () B) imperatividade.
- () C) auto-executoriedade.
- () D) legalidade.

Q1040970

Ano: 2019 Banca: FGV Órgão: OAB Prova: FGV - 2019 - OAB - Exame de Ordem Unificado XXX - Primeira Fase

José, servidor público federal ocupante exclusivamente de cargo em comissão, foi exonerado, tendo a autoridade competente motivado o ato em reiterado descumprimento da carga horária de trabalho pelo servidor. José obteve, junto ao departamento de recursos humanos, documento oficial com extrato de seu ponto eletrônico, comprovando o regular cumprimento de sua jornada de trabalho.

Assim, o servidor buscou assistência jurídica junto a um advogado, que lhe informou corretamente, à luz do ordenamento jurídico, que:

- () A) não é viável o ajuizamento de ação judicial visando a invalidar o ato de exoneração, eis que o próprio texto constitucional estabelece que cargo em comissão é de livre nomeação e exoneração pela autoridade competente, que não está vinculada ou limitada aos motivos expostos para a prática do ato administrativo.
- () B) não é viável o ajuizamento de ação judicial visando a invalidar o ato de exoneração, eis que tal ato é classificado como vinculado, no que tange à liberdade de ação do administrador público, razão pela qual o Poder Judiciário não pode se imiscuir no controle do mérito administrativo, sob pena de violação à separação dos Poderes.
- () C) é viável o ajuizamento de ação judicial visando a invalidar o ato de exoneração, eis que, apesar de ser dispensável a motivação para o ato administrativo discricionário de exoneração, uma vez expostos os motivos que conduziram à prática do ato, estes passam a vincular a Administração Pública, em razão da teoria dos motivos determinantes.
- () D) é viável o ajuizamento de ação judicial visando a invalidar o ato de exoneração, eis que, por se tratar de um ato administrativo vinculado, pode o Poder Judiciário proceder ao exame do mérito administrativo, a fim de aferir a conveniência e a oportunidade de manutenção do ato, em razão do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional.

Q626472

Ano: 2016 Banca: FGV Órgão: OAB Prova: FGV - 2016 - OAB - Exame de Ordem Unificado - XIX - Primeira Fase

A associação de moradores do Município F solicitou ao Poder Público municipal autorização para o fechamento da "rua de trás", por uma noite, para a realização de uma festa junina aberta ao público. O Município, entretanto, negou o pedido, ao fundamento de que aquela rua seria utilizada para sediar o encontro anual dos produtores de abóbora, a ser realizado no mesmo dia.

Considerando que tal fundamentação não está correta, pois, antes da negativa do pedido da associação de moradores, o encontro dos produtores de abóbora havia sido transferido para o mês seguinte, conforme publicado na imprensa oficial, assinale a afirmativa correta.

- () A) Mesmo diante do erro na fundamentação, o ato é válido, pois a autorização pleiteada é ato discricionário da Administração.
- () B) Independentemente do erro na fundamentação, o ato é inválido, pois a autorização pleiteada é ato vinculado, não podendo a Administração indeferi-lo.
- () C) Diante do erro na fundamentação, o ato é inválido, uma vez que, pela teoria dos motivos determinantes, a validade do ato está ligada aos motivos indicados como seu fundamento.
- () D) A despeito do erro na fundamentação, o ato é válido, pois a autorização pleiteada é ato vinculado, não tendo a associação de moradores demonstrado o preenchimento dos requisitos.

Q205203

Ano: 2008 Banca: CESPE Órgão: OAB-SP Prova: CESPE - 2008 - OAB-SP - Exame de Ordem - 1 - Primeira Fase

Com relação aos diversos aspectos que regem os atos administrativos, assinale a opção correta.

- () A) Segundo a teoria dos motivos determinantes do ato administrativo, o motivo do ato deve sempre guardar compatibilidade com a situação de fato que gerou a manifestação de vontade, pois, se o interessado comprovar que inexistente a realidade fática mencionada no ato como determinante da vontade, estará ele irremediavelmente inquinado de vício de legalidade.
- () B) Motivo e motivação do ato administrativo são conceitos equivalentes no direito administrativo.
- () C) Nos atos administrativos discricionários, todos os requisitos são vinculados.
- () D) A presunção de legitimidade dos atos administrativos é uma presunção jure et de jure, ou seja, uma presunção absoluta.

Q205103

Ano: 2008 Banca: CESPE Órgão: OAB-SP Prova: CESPE - 2008 - OAB-SP - Exame de Ordem - 2 - Primeira Fase

Não configura, segundo a doutrina dominante, elemento ou requisito do ato administrativo:

- () A) a forma.
- () B) o objeto.
- () C) a finalidade.
- () D) a discricionariedade.

Q299409

Ano: 2007 Banca: CESPE Órgão: OAB Prova: CESPE - 2007 - OAB - Exame de Ordem - 2 - Primeira Fase

Acerca dos atos administrativos, assinale a opção correta.

- () A) Os atos administrativos são praticados apenas pela administração pública.
- () B) Os atos de caráter normativo, de decisão de recurso administrativo e os de matérias de competência exclusiva, nos termos da Lei n.º 9.784/1999, não são passíveis de delegação.
- () C) Se o motivo que determina e justifica a prática do ato é inexistente ou é inválido, inválidos serão apenas os efeitos do ato e não o próprio ato em si.
- () D) Os elementos do ato administrativo que se referem ao mérito são o objeto e a finalidade.

Q542953

Ano: 2012 Banca: FGV Órgão: OAB Prova: FGV - 2012 - OAB - Exame de Ordem Unificado - VI - Primeira Fase - Reaplicação

A decisão tomada por uma das Câmaras do Conselho de Contribuintes de determinada Administração Estadual é considerada ato:

- () A) composto, pois resulta da manifestação de mais de um agente público.
- () B) complexo, pois depende da manifestação de aprovação, com o relator, de outros agentes.
- () C) qualificado, pois importa na constituição da vontade da Administração quanto a matéria específica.
- () D) simples, pois resulta da manifestação de vontade de um órgão dotado de personalidade administrativa.

Q171058

Ano: 2010 Banca: CESPE Órgão: OAB Prova: CESPE - 2010 - OAB - Exame de Ordem - 3 - Primeira Fase

De acordo com a classificação dos atos administrativos, constitui ato de gestão:

- () A) a apreensão de bens.
- () B) o negócio contratual.
- () C) o decreto de regulamentação.
- () D) o embargo de obra.

Q318809

Ano: 2008 Banca: CESPE Órgão: OAB Prova: CESPE - 2008 - OAB - Exame de Ordem - 3 - Primeira Fase

Considerando que há evidentes elementos de identidade entre ato jurídico e ato administrativo, e que este é espécie do gênero ato jurídico, assinale a opção correta.

- () A) Existem atos praticados pelos administradores públicos que não se enquadram como atos administrativos típicos, como é o caso dos contratos disciplinados pelo direito privado.

- () B) Atos administrativos, atos da administração e atos de gestão administrativa são expressões sinônimas.
- () C) O exercício de cargo público em caráter efetivo é *conditio sine quae non* para prática do ato administrativo.
- () D) Mesmo nos casos em que o administrador público contrata com o particular em igualdade de condições, está caracterizado o ato administrativo, pois a administração pública está sendo representada por seu agente.

Q318808

Ano: 2008 Banca: CESPE Órgão: OAB Prova: CESPE - 2008 - OAB - Exame de Ordem - 3 - Primeira Fase

Encontra-se sedimentado o entendimento de que ao Poder Judiciário é defeso apreciar o mérito dos atos administrativos, limitando sua atuação quanto à aferição dos aspectos relativos à sua legalidade. A esse respeito, assinale a opção correta.

- () A) A garantia constitucional de que ninguém será obrigado a deixar de fazer algo senão em virtude de lei assegura ao administrador público ilimitada discricionariedade na escolha dos critérios de conveniência e oportunidade nos casos de anomia.
- () B) Embora discricionariedade e arbitrariedade sejam espécies do mesmo gênero e, portanto, legítimas, apenas a segunda é passível de controle de legalidade em sentido estrito.
- () C) O abuso de poder e a arbitrariedade têm como traço de distinção o fato de que aquele se sujeita ao controle judicial e esta, somente à revisão administrativa.
- () D) Não há discricionariedade *contra legem*.

Q207863

Ano: 2007 Banca: VUNESP Órgão: OAB-SP Prova: VUNESP - 2007 - OAB-SP - Exame de Ordem - 2 - Primeira Fase

Sobre os atos administrativos discricionários, é incorreto afirmar que:

- () A) são resultados da liberdade de atuação do administrador nos limites traçados pela lei.
- () B) são objetos de controle de legalidade pelo Poder Judiciário.
- () C) são atos arbitrários, praticados pelo administrador com base em seu Poder de Polícia.
- () D) têm no desvio de poder um dos limites a sua prática concreta.

Q299620

Ano: 2006 Banca: CESPE Órgão: OAB Prova: CESPE - 2006 - OAB - Exame de Ordem Julgue os seguintes itens, referentes a atos administrativos.

I. Ato vinculado ou regrado é aquele para cuja realização a lei estabelece requisitos e condições.

II. Ato discricionário pode ser praticado pela administração com liberdade de escolha de seu conteúdo, de seu destinatário, de sua conveniência, de sua oportunidade e do modo de sua realização.

III. Ato nulo é aquele que a administração, e somente ela, pode invalidar, por motivo de conveniência, oportunidade ou justiça.

IV. Ato revogável é o que nasce afetado de vício insanável por ausência ou defeito substancial em seus elementos constitutivos ou em seu procedimento formativo.

Estão certos apenas os itens:

- () A) I e II.
- () B) I e III.
- () C) II e IV.
- () D) III e IV.